

e internacionales, presentar exposiciones orales y escritas ante la CIJ en ocasión de los dictámenes pedidos a dicho órgano judicial, y poder llamar la atención del Consejo de Seguridad hacia cualquier asunto que en su opinión pueda poner en peligro el mantenimiento de la paz y seguridad internacionales⁸⁴.

Una de las funciones más vitales que desempeña el secretario general es la utilización de sus buenos oficios, es decir, la adopción de medidas, en público y en privado, basadas en su independencia, imparcialidad e integridad, para evitar que surjan, aumenten o se extiendan las controversias internacionales.

CAPÍTULO 4

FUENTES Y NORMAS

DEL DERECHO INTERNACIONAL

Silvina S. González Napolitano

1. Introducción: las fuentes de derecho

Las normas jurídicas se crean y expresan, tanto en los ordenamientos internos como en el derecho internacional, a través de determinados "medios" (constituciones nacionales, leyes, tratados internacionales, etc.), los cuales se denominan "fuentes de derecho" o "fuentes jurídicas".

Sin embargo, es de destacar que la palabra "fuente" ha sido utilizada con distintos significados. Se trata de un concepto ambiguo que nos lleva a referirnos a las fuentes materiales y a las formales.

Las fuentes materiales son los fundamentos extrajurídicos de una norma jurídica, es decir, las causas que la motivan u originan¹. Por ejemplo, las posturas políticas, sociales o culturales que llevaron a la creación de determinada regla de derecho.

En cuanto a las fuentes formales, en sentido restringido, serían los medios o procesos para la creación del derecho; en sentido amplio, serían aquellas "a través de las cuales el derecho se manifiesta y formula y en razón de ser su expresión visible y concreta, se definen como los modos de verificación de la existencia de normas jurídicas"².

Las fuentes formales presentan dos modalidades del proceso de creación del derecho: una deliberada y la otra espontánea³. La costumbre constituye una fuente formal de creación espontánea del derecho.

2. Las fuentes del derecho internacional y su clasificación

Una de las características del derecho internacional es su carácter descentralizado, lo que presupone la inexistencia de un órgano legislativo mundial que dicte normas jurídicas vinculantes para toda la comunidad internacional. Es así que los Estados crean las normas internacionales a través de distintos mecanismos descentralizados (por ejemplo, mediante tratados o cierta práctica -costumbre-). También los Estados delegan la facultad de crear normas internacionales en otros sujetos, como, por ejemplo, las organizaciones internacionales.

84 Carta de las Naciones Unidas, artículo 99.

1 Ofr. Moncayo, Guillermo; Vinuesa, Raúl y Gutiérrez Posse, Hortensia, *Derecho Internacional Público*, Zava-
lla, Buenos Aires, t. I, 2.ª reimpr., 1987, pp. 75-77.

2 *Ibid.*, p. 76.

3 Ofr. Nino, Carlos, *Introducción al Análisis del Derecho*, Astrea, Buenos Aires, 2.ª edic., 1984, p. 149.

Las fuentes formales del derecho internacional –en sentido amplio– pueden clasificarse en principales y auxiliares. En sentido restringido, las auxiliares no serían consideradas “fuentes”, sino “medios” auxiliares.

Las fuentes principales –creadoras– del derecho internacional en general son los tratados internacionales, la costumbre internacional y los principios generales de derecho. La doctrina y la jurisprudencia son fuentes o medios auxiliares en la determinación de las reglas de derecho, pero no constituyen fuentes principales, es decir, no son creadoras de derecho.

2.1. Enunciación

En general, se acepta que el punto de partida para la enunciación de las fuentes del derecho internacional es el artículo 38 del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia (ECIJ), aunque llamativamente no haga referencia a la palabra “fuente”. En efecto, dicho artículo dispone:

1. La Corte, cuya función es decidir conforme al derecho internacional las controversias que le sean sometidas, deberá aplicar:
 - a. las convenciones internacionales, sean generales o particulares, que establecen reglas expresamente reconocidas por los Estados litigantes;
 - b. la costumbre internacional como prueba de una práctica generalmente aceptada como derecho;
 - c. los principios generales de derecho reconocidos por las naciones civilizadas;
 - d. las decisiones judiciales y las doctrinas de los publicistas de mayor competencia de las distintas naciones, como medio auxiliar para la determinación de las reglas de derecho, sin perjuicio de lo dispuesto en el Artículo 59.
2. La presente disposición no restringe la facultad de la Corte para decidir un litigio *ex aequo et bono*, si las partes así lo convinieren.

Esta disposición tiene su origen en el homónimo artículo contenido en el Estatuto de la predecesora de la CIJ –la Corte Permanente de Justicia Internacional–, creada en 1920 bajo los auspicios de la Sociedad de las Naciones.

La referencia al derecho internacional incluida en el inciso 1 denota que las fuentes enunciadas en dicho párrafo no son otras que las fuentes del derecho internacional. De hecho, varios instrumentos internacionales hacen referencia expresa al artículo 38 de los Estatutos de la CPJI y la CIJ al establecer el derecho que deberá aplicar el tribunal arbitral que resuelva la disputa⁴.

El artículo 38(1) del ECIJ, en sus apartados a, b y c, enuncia las fuentes principales del derecho internacional: los tratados internacionales, la costumbre internacional y los principios generales de derecho, que serán tratadas con mayor detenimiento en los capítulos siguientes de esta obra.

Los tratados internacionales son acuerdos de voluntades entre dos o más sujetos de derecho internacional con capacidad para celebrar tratados⁵, con el fin de crear, modificar o extinguir derechos u obligaciones internacionales y regidos por el derecho internacional. Cuando el artículo 38 del ECIJ menciona esta fuente, lo hace de la siguiente manera: “[...] las convenciones internacionales, sean generales o particulares, que establecen reglas expresamente reconocidas por los Estados litigantes”. La alusión a “Estados litigantes” es entendible por cuanto el artículo 38 está destinado a ser aplicado en el marco de una controversia sometida ante la

Corte –aunque las fuentes allí enunciadas también son consideradas por dicho tribunal en el marco de un procedimiento consultivo–.

La costumbre internacional ha sido definida como “la práctica común y reiterada de dos o más Estados aceptada por éstos como obligatoria”. Sin embargo, el artículo 38(1)(b) del ECIJ se refiere a ella “como prueba de una práctica generalmente aceptada como derecho”, lo que ha llevado a los académicos a preguntarse acerca de si la costumbre es la prueba de la práctica o, al revés, la práctica es la prueba de la costumbre, como veremos en el capítulo 5 de esta obra.

Los principios generales de derecho son postulados, máximas rectoras del derecho en general, que se encuentran en todos los ordenamientos jurídicos internos, en el sistema jurídico de todos los Estados. El artículo 38(1)(c) del ECIJ alude a los “principios generales de derecho reconocidos por las naciones civilizadas”. La referencia al reconocimiento por parte de las “naciones civilizadas” hoy es viciosa como redundante; en sus orígenes, con ella se pretendía excluir a los sistemas de derecho de las comunidades “primitivas”.

El artículo 38(1)(d) menciona los medios auxiliares: la jurisprudencia y la doctrina.

La jurisprudencia comprende las decisiones (providencias o resoluciones y sentencias) de las cortes o tribunales. Así, la jurisprudencia internacional es el conjunto de decisiones y/o fallos de los tribunales (o cortes) internacionales.

La doctrina es la opinión de los juristas. El artículo 38(1)(d) se refiere a ella como a “las doctrinas de los publicistas de mayor competencia de las distintas naciones”. Podemos decir que la doctrina internacional es la opinión de los juristas reconocidos en el ámbito académico internacional. Puede tratarse tanto de la opinión individual de un experto en derecho como de la posición de una institución académica internacional, como es el Institut de Droit International, o, incluso, de una organización no gubernamental, como Amnistía Internacional.

La referencia a “decidir un litigio *ex aequo et bono*”, contenida en el inciso 2 del artículo 38, implica darle la potestad al tribunal para que dicte un fallo conforme a equidad, lo que se analizará con mayor detalle en el capítulo 10 de esta obra.

Se ha discutido si esta enumeración (contenida en el art. 38, ECIJ) es o no taxativa, principalmente por el hecho de que no están enumerados de manera explícita las resoluciones de los organismos internacionales o los actos unilaterales de los Estados, muchos de los cuales son fuentes del derecho internacional. Los autores que consideran que el artículo 38 no es taxativo se basan justamente en estas omisiones⁶.

Por el contrario, para quienes el artículo 38 es taxativo, el fundamento es que las resoluciones obligatorias de los organismos internacionales encuentran sustento en última instancia en el tratado base, que es una fuente expresamente enumerada en aquella disposición. Así, una resolución del Consejo de Seguridad sería vinculante porque así lo dispone el artículo 25 del tratado que crea a dicho órgano, es decir, la Carta de las Naciones Unidas. Por lo tanto, la fuente sería el tratado. Sin embargo, también se ha señalado que en ocasiones la relación entre la resolución y el tratado puede no ser tan próxima: por ejemplo, un tribunal puede tener que interpretar una resolución dictada por un órgano subsidiario que no ha sido creado directamente por un tratado, sino por resolución de otro órgano⁷. De ahí que se sostenga que aplicar una resolución es algo distinto que aplicar un tratado, siendo la más obvia diferencia que no hay Estados parte en una resolución⁸.

Respecto de los actos unilaterales del Estado, tampoco explicitados en el artículo 38, algunos autores sostienen: “[...] en razón del carácter taxativo de su enunciado, ninguna sentencia de este tribunal podrá fundarse exclusivamente en una norma jurídica supuestamente creada

4 Hillier, Tim, *Sourcebook on Public International Law*, Cavendish Publishing, Londres, Sidney, 1998, pp. 63-64.

5 Al respecto, Pellet menciona el artículo 28 del Acta General de Ginebra sobre Solución Pacífica de Controversias (1928) y el artículo 38 del Acta General de Ginebra revisada (1948); Pellet, Alain, “Article 38”, en *The Statute of the International Court of Justice. A Commentary*, Zimmermann, Andreas; Tomuschat, Christian y Oellers-Frahm, Karin (eds.), Oxford University Press, Oxford, 2006, p. 691.

6 No todos los sujetos del derecho internacional poseen esta capacidad, como se observó en el capítulo 2.

7 Moncayo, Guillermo; Vinuesa, Raúl y Gutiérrez Posse, Hortensia, *op. cit.*, p. 82.

8 Cheng, Bin, *General Principles of Law as Applies to International Courts and Tribunals*, Grotius, Cambridge, 1987, p. 25.

9 Wolfrum, Rüdiger, “Sources of international law” (2012), en *Max Planck Encyclopedia of Public International Law*, <http://www.mpepil.com>, párr. 10.

10 Tammes, Arnold, “Decisions of International organs as a source of International law”, *R.C.A.D.I.*, vol. 94 (1958), p. 269.

11 *Ibid.*, p. 270.

por un acto unilateral de un Estado"¹². En cuanto al fallo dictado en los casos de los *Ensayos nucleares*, en el cual la CIJ reconoció que la declaración unilateral de Francia tenía efectos vinculantes –como se analizará en el capítulo 11 de esta obra–, aquellos autores afirman que “tal declaración crea ‘una obligación jurídica individual’ que no necesita aceptación, ni siquiera una respuesta o reacción de otros Estados”, que “descansa según la Corte en el principio de buena fe”. En consecuencia, “Nos hallaríamos entonces ante un acto generador de una obligación individual que produce este efecto jurídico en razón de aplicar una norma positiva general como lo es la obligación de actual de buena fe”, la cual “constituye un principio general de derecho de los reconocidos como fuente autónoma por el art. 38, 1.c) del Estatuto de la C.I.J.”¹³. Para tales juristas, entonces, el artículo 38 sigue siendo taxativo, puesto que los actos unilaterales no serían una fuente autónoma, independientemente de que puedan generar obligaciones basadas en otra de las fuentes enumeradas de manera expresa en tal disposición.

También se ha debatido en cuanto a la obligatoriedad de las fuentes contenidas en el artículo 38 del ECIJ. Nótese que el inciso 1 de dicho artículo establece que la Corte “deberá aplicar” las fuentes que allí se mencionan, por lo que se afirma que, por lo menos para ese tribunal, dichas fuentes son obligatorias¹⁴.

El hecho de que el artículo 38(1) haga referencia solamente a la competencia contenciosa de la Corte al expresar: “[...] cuya función es decidir conforme al derecho internacional las controversias que le sean sometidas [...]” no es óbice para que la CIJ se guíe por él cuando ejerza su competencia consultiva. Justamente el artículo 66 del ECIJ dispone: “En el ejercicio de sus funciones consultivas, la Corte se guiará además por las disposiciones de este Estatuto que rijan en materia contenciosa, en la medida en que la propia Corte las considere aplicables”, por lo que se entiende que el artículo 38 es una de esas disposiciones¹⁵.

Podría decirse que, en principio, la Corte Internacional de Justicia cuando resuelve controversias está obligada a aplicar las fuentes contenidas en este artículo. Sin embargo, como no se trata de una norma imperativa, los Estados pueden convenir –sea en un tratado sobre una materia específica, sea en un compromiso para someter una controversia a un tribunal– las fuentes a ser aplicadas por los tribunales internacionales en caso de disputa. Por ejemplo, el artículo 293 de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CONVEMAR) establece que los tribunales que tengan jurisdicción para resolver una disputa en el marco de dicha Convención (uno de ellos puede ser la propia Corte Internacional de Justicia), deberán aplicar “[esa] Convención y las demás normas de derecho internacional que no sean incompatibles con ella”, salvo que se le hubiese otorgado el poder para fallar *ex aequo et bono*.

Por su parte, el Convenio sobre Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones entre Estados y Nacionales de Otros Estados (1965) (Convenio CIADI), dispone en su artículo 42 que los tribunales arbitrales constituidos de conformidad con dicho Convenio decidirán la diferencia “de acuerdo con las normas de derecho acordadas por las partes. A falta de acuerdo, el Tribunal aplicará la legislación del Estado que sea parte en la diferencia, incluyendo sus normas de derecho internacional privado, y aquellas normas de derecho internacional que pudieren ser aplicables”, dejando también a salvo que se le hubiese otorgado el poder para fallar *ex aequo et bono*. La referencia al derecho interno en el artículo 42 del Convenio CIADI, como parte del derecho a aplicar por el tribunal, es entendible, puesto que no se trata de la resolución de controversias interestatales, sino de disputas en materia de inversiones extranjeras entre Estados y personas físicas o jurídicas nacionales de otros Estados. El artículo 38 del ECIJ hace solo referencia a las fuentes del derecho internacional porque fue pensado exclusivamente para la solución de controversias entre Estados¹⁶.

12 Moncayo, Guillermo; Vinuesa, Raúl y Gutiérrez Posse, Hortensia, *op. cit.*, p. 61.

13 *Ibid.*, p. 62.

14 *Ibid.*, pp. 78-79.

15 Pellet, Alain, *op. cit.*, p. 694.

16 *Ibid.*, p. 692.

2.2. Jerarquía

Comúnmente, los académicos sostienen que no hay una jerarquía rígida entre las fuentes principales; el orden en el que fueron enunciadas en el ECIJ sería el orden lógico o práctico en general seguido por los tribunales internacionales al resolver una controversia¹⁷. Así, los jueces verificarían primero la existencia de tratados; segundo, las normas consuetudinarias y, por último, los principios generales de derecho que resulten aplicables.

El problema se presenta cuando existe conflicto de normas de igual jerarquía, como, por ejemplo, un tratado incompatible con la práctica seguida por los Estados en cuestión. En dicho supuesto, ¿qué norma prevalece? A menos que las partes litigantes hubiesen convenido otra cosa, una posible solución sería recurrir a los principios generales de derecho “ley posterior deroga ley anterior” y “ley especial deroga ley general”, de modo que prevalezca la norma posterior o la norma especial¹⁸, independientemente del tipo de fuente. Así, un tratado podría caer en desuetud –entre todas o algunas de sus partes– al ser sus normas reemplazadas por una costumbre posterior.

Cabe recordar que las normas imperativas de derecho internacional general (*jus cogens*) prevalecen siempre sobre las normas dispositivas, cualquiera sea la fuente por la cual estas últimas hubieran sido creadas.

3. Medios auxiliares para la determinación de las reglas de derecho internacional

3.1. La jurisprudencia

Puede observarse que el artículo 38(1)(d) del ECIJ alude a la jurisprudencia como “las decisiones judiciales”, sin mencionar a las arbitrales. Debe entenderse, sin embargo, que este medio auxiliar comprende tanto las decisiones de los tribunales judiciales como las arbitrales.

Dicha disposición tampoco se ha restringido a las decisiones dictadas por tribunales “internacionales”. Por ello, se ha argumentado que, si una decisión de un tribunal interno de un Estado resulta relevante, puede ser tomada en cuenta por el tribunal internacional¹⁹. Ello sin perjuicio de que la jurisprudencia interna de un Estado pueda ser citada como prueba de la existencia de una costumbre internacional o de un principio general de derecho.

En ocasiones la expresión jurisprudencia se ha empleado con un alcance mucho más amplio, incluyendo las decisiones de organismos cuasijurisdiccionales, como, por ejemplo, los órganos de vigilancia de algunos tratados sobre derechos humanos (Comité contra la Tortura, Comisión Interamericana de Derechos Humanos, etc.).

Tal como dispone el artículo 59 del ECIJ, los fallos judiciales son obligatorios solo respecto de los casos en los que se han dictado y para las partes en tales asuntos –artículo al cual se remite el artículo 38(1)(d)–, pero no son obligatorios para casos futuros, tal como acontece en el derecho anglosajón. Cuando el artículo 38(1) aclara que la función de la Corte es “decidir conforme al derecho internacional las controversias que le sean sometidas”, precisamente lo hace para recordar que el tribunal no posee funciones legislativas, sino judiciales²⁰; no puede crear derecho internacional, sino resolver las controversias de acuerdo con el derecho internacional creado antes por las fuentes reconocidas.

Sin embargo, un tribunal internacional puede recurrir a la jurisprudencia sentada por dicho órgano, o incluso por otros tribunales internacionales, “no para fundar exclusivamente en ella la norma que ha de aplicar, sino para determinar con su auxilio si ha surgido realmente

17 Hillier, Tim, *op. cit.*, p. 84.

18 Wolfrum, Rüdiger, *op. cit.*, parág. 11; Moncayo, Guillermo; Vinuesa, Raúl y Gutiérrez Posse, Hortensia, *op. cit.*, p. 81.

19 Hillier, Tim, *op. cit.*, p. 84.

20 Pellet, Alain, *op. cit.*, p. 690.

una costumbre jurídica sobre un punto dado, o si existe un principio general de derecho generalmente recibido²¹.

Se ha discutido acerca de si los jueces crean o no derecho a través de una sentencia²² y si la jurisprudencia²³ es o no fuente de derecho²⁴. Sin duda, tanto la jurisprudencia como la doctrina²⁵ constituyen fuentes formales en el sentido amplio del término, es decir, como modos de verificación de una norma jurídica, puesto que evidencian la existencia de una norma que ha sido creada mediante uno de los procesos válidos (fuentes en sentido restringido, es decir, "creadoras")²⁶.

El estudio de la jurisprudencia internacional es de suma importancia, ya que nos ayuda a conocer la forma en que los jueces aplican —o los motivos por los que dejan de aplicar— determinadas normas, así como sus límites. Aunque hay que tener en cuenta que, al no estar obligados los magistrados y árbitros por sus propios precedentes, existe la posibilidad de que en el futuro asuman una posición distinta respecto de una misma norma jurídica. En efecto, la doctrina del *stare decisis* (precedente obligatorio) —seguida por el derecho anglosajón— no se aplica en el derecho internacional²⁷.

En cualquier caso, los precedentes pueden tener una fuerza persuasiva al resolverse futuros casos e influir en el mejor entendimiento del derecho²⁸. Así, Mendelson sostiene que las decisiones de los tribunales "pueden ser citadas como evidencia de la *opinio juris* prevaleciente sobre una cuestión particular" y agrega que la propia CIJ, al igual que otros tribunales, "considera legítimo tomar en cuenta no sólo las opiniones de Estados, sino también de otros participantes del proceso legal internacional, lo cual incluye a los tribunales internacionales y hasta los nacionales (en circunstancias apropiadas)"²⁹. Aunque es cierto que la CIJ rara vez suele citar como autoridad decisiones de otros tribunales y mucho menos de un tribunal interno³⁰ —y cuando ha hecho esto último fue para hacer referencia a una sentencia local invocada expresamente por las partes litigantes³¹—.

Si bien se ha afirmado que es más apropiado que la CIJ considere sus propios fallos u opiniones consultivas (o de su predecesora, la CPJI) como guía para futuros casos, ello no impide que se aparte de esa práctica y se refiera a fuentes externas³². Por ejemplo, en la *Opinión consultiva sobre las consecuencias jurídicas de la construcción de un muro en el territorio palestino ocupado*, la Corte se apoyó en la interpretación dada por el Comité de Derechos Humanos, órgano de vigilancia del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, respecto del alcance del ámbito de aplicación territorial de dicho tratado³³.

21 Cfr. Jiménez de Aréchaga, Eduardo, *Derecho Internacional Público*, Fundación de Cultura Universitaria, Montevideo, t. 1, 1.ª edic., 1993, p. 182.

22 Var Nino, Carlos, *op. cit.*, pp. 149-150.

23 O sea, el conjunto de decisiones judiciales concordantes.

24 Para Nino la jurisprudencia es una forma espontánea de dar origen a normas jurídicas (Nino, Carlos, *op. cit.*, p. 151). Sin embargo, considera que en nuestro sistema jurídico, de tipo continental europeo, a diferencia del anglosajón, "los jueces buscan orientación en la jurisprudencia, pero en general no consideran que los precedentes tengan fuerza imperativa para futuras decisiones" (*ibid.*, p. 152). Ello sin perjuicio del reconocimiento de la obligatoriedad de los fallos plenarios para las salas que componen una cámara de apelaciones, con el objeto de unificar posiciones contradictorias (*ibid.*, pp. 152-153).

25 Es decir, la opinión de los juristas.

26 Cfr. Moncayo, Guillermo; Vinuesa, Raúl y Gutiérrez Posse, Hortensia, *op. cit.*, p. 78.

27 Acquaviva, Guido y Pocar, Fausto, "Stare decisis" (2009), en *Max Planck Encyclopedia of Public International Law*, <http://www.mpepil.com>, párr. 24.

28 Mendelson, Maurice, "The International Court of Justice and the sources of international law", en *Fifty years of the International Court of Justice. Essays in honour of Sir Robert Jennings, Lowe, Vaughan y Fitzmaurice*, Malgosa, Cambridge University Press, Cambridge, 1993, p. 81.

29 *Ibid.*, p. 82 (traducción libre).

30 *Ibid.*, pp. 82-83.

31 *Orden de arresto del 11 de abril de 2000* (República Democrática del Congo c. Bélgica), CIJ, Fallo, 14/02/2002, párrs. 56-57, donde se hace referencia a una decisión de la Cámara de los Lores británica dictada en el caso *Pinochet*, citada por las partes.

32 Acquaviva, Guido y Pocar, Fausto, *op. cit.*, párrs. 12 y 23.

33 *Consecuencias jurídicas de la construcción de un muro en el territorio palestino ocupado*, CIJ, Opinión Consultiva, 09/07/2004, par. 109. La Corte cita varios casos en los cuales el Comité determinó que el Pacto es aplicable cuando el Estado ejerce su jurisdicción en territorio extranjero, como, por ejemplo, los casos *López Burgos contra el Uruguay* (n.º 52/79), *Lilian Celiberti de Casariego contra el Uruguay* (n.º 56/79) y *Montero contra el Uruguay* (n.º 106/81).

A diferencia de la CIJ, otros tribunales frecuentemente citan las decisiones judiciales o arbitrales de otros órganos. Tal el caso del Tribunal Internacional del Derecho del Mar, de los tribunales de derechos humanos, de los tribunales penales internacionales o de varios tribunales arbitrales³⁴.

Como se ha dicho, nada impide a los jueces o árbitros internacionales cambiar de posición y resolver una cuestión de manera distinta a como lo han hecho en una controversia anterior. Sobre esto último hay bastante jurisprudencia en los arbitrajes de inversión³⁵. Aunque, en la Corte Internacional de Justicia, con acierto se ha señalado que, cuando en un caso no sigue los razonamientos y conclusiones de asuntos previos, nunca explicita que se aparta de ellos, sino que prefiere de manera implícita distinguir a dicho asunto de los otros³⁶.

Se ha afirmado que los tribunales internacionales tienden a aplicar sus propias decisiones previas con el fin de asegurar consistencia y predicción, pero así también las de otros órganos que traten cuestiones de derecho similares, para mantener la unidad del sistema jurídico internacional³⁷.

3.2. La doctrina

Aunque con menor peso que la propia jurisprudencia, la doctrina también auxilia a los jueces y abogados en la verificación del contenido e interpretación de las normas jurídicas. Si bien es cierto que algunos tribunales internacionales son reticentes a citar artículos u obras bibliográficas con el fin de avalar sus conclusiones.

Así, sin mencionar autores en particular, la Corte Permanente de Justicia Internacional, en el caso *Lotus*, se refirió a la doctrina del siguiente modo:

En primer lugar, en lo que concierne a la doctrina, y cualquiera que pueda ser su valor en cuanto a tratar de constatar la existencia de una regla de derecho consuetudinario, no caben dudas de que todos o casi todos los autores enseñan que los buques en alta mar están sujetos exclusivamente a la jurisdicción del Estado de la bandera que enarbolan. Pero lo que importa es el significado que le dan a este principio; ahora bien, no parece que, generalmente, los autores otorguen a este principio un alcance diferente y más extenso que el que se expuso más arriba, y que equivale a decir que la jurisdicción del Estado sobre los buques en alta mar tiene la misma extensión que la jurisdicción sobre su propio territorio. Por el contrario, no faltan autores que, al examinar de cerca la cuestión especial de saber si un Estado puede juzgar delitos cometidos a bordo de un buque extranjero en alta mar, definitivamente lleguen a la conclusión que estos delitos deben ser considerados como si hubieran sido cometidos en el territorio del Estado cuya bandera enarbolan, por lo que, por consiguiente, son aplicables las reglas generales de cada sistema jurídico respecto de los delitos cometidos en el extranjero³⁸.

34 Ver, a título de ejemplo, los casos citados en Acquaviva, Guido y Pocar, Fausto, *op. cit.*, párr. 28.

35 Por ejemplo, el tribunal arbitral del CIADI que intervino en el caso *CMS c. Argentina*, falló que no correspondía aplicar una norma del TBI Argentina-Estados Unidos (art. xi) para eximir de responsabilidad a la República Argentina por las medidas de emergencia tomadas para hacer frente a la crisis surgida en 2001-2002. Uno de los tres árbitros que integró ese tribunal también integró otro tribunal arbitral, que sostuvo lo contrario en el caso *LG&E c. Argentina*. Las votaciones en ambos casos fueron por unanimidad. Meses más tarde, otro de los árbitros que integró el tribunal de *LG&E* votó de manera contraria en el caso *Sempra c. Argentina*, cuyo laudo también se adoptó por unanimidad. Ver *CMS Gas Transmission Company c. República Argentina* (caso CIADI N.º ARB/01/08), Laudo, 12/05/2006, par. 381; *LG&E Energy Corp., LG&E Capital Corp. y LG&E International, Inc. c. República Argentina* (caso CIADI N.º ARB/02/1), Decisión sobre responsabilidad, 08/10/2006, par. 239; *Sempra Energy International c. República Argentina* (caso CIADI N.º ARB/02/18), Laudo, 28/07/2007, par. 355.

36 Acquaviva, Guido y Pocar, Fausto, *op. cit.*, párr. 13. En este artículo se cita el fallo de excepciones preliminares dictado en el caso de la *Frontera terrestre y marítima entre Camerún y Nigeria*, donde la CIJ sostuvo que "La cuestión real es si, en este caso, hay razón para no seguir los razonamientos y las conclusiones de casos anteriores"; *Frontera terrestre y marítima entre el Camerún y Nigeria* (Camerún c. Nigeria), CIJ, Excepciones Preliminares, Fallo, 11/06/1998, par. 28 (traducción libre).

37 Acquaviva, Guido y Pocar, Fausto, *op. cit.*, párr. 24.

38 *S.S. Lotus* (Francia c. Turquía), CPJI, Fallo, 07/09/1927, *CPJI Serie A*, n.º 10, p. 26 (traducción libre).

En cuanto a la Corte Internacional de Justicia, no se observan referencias a escritos de juristas en los fallos que representan el voto de la mayoría de los jueces, pero suelen encontrarse muchas citas doctrinarias en los votos separados o en disidencia efectuados por algunos magistrados³⁹.

Por el contrario, en las decisiones de otros tribunales judiciales pueden hallarse citas de obras y artículos de diversos doctrinarios. En tal sentido, la Corte Interamericana de Derechos Humanos suele referirse tanto a escritos de académicos como a informes de organizaciones no gubernamentales que contienen estudios sobre determinadas violaciones a los derechos humanos⁴⁰.

En los laudos de los tribunales arbitrales también es frecuente encontrar citas de obras y artículos bibliográficos⁴¹.

4. Normas del derecho internacional

Aunque la expresión no está libre de ambigüedades⁴², puede decirse que **una norma jurídica es una conducta debida (o prescrita) a través de una de las fuentes de derecho**.

Las normas cumplen distintas funciones en un sistema jurídico, **algunas otorgan derechos o imponen obligaciones, otras prescriben la aplicación de sanciones u otorgan competencia para aplicar sanciones; incluso hay normas que facultan para dictar otras normas**⁴³. Esto también ocurre en el derecho internacional⁴⁴.

4.1. Clasificación de las normas internacionales

Las normas internacionales suelen ser clasificadas de acuerdo con distintos parámetros. A continuación nos referiremos a las clasificaciones más utilizadas en la práctica del derecho internacional.

Según su alcance personal y/o territorial, las normas pueden ser, por un lado, generales o particulares, y por el otro, bilaterales o multilaterales.

Las normas *generales* son aquellas que vinculan a toda o a casi toda la comunidad internacional, independientemente de si los sujetos obligados participaron o no en el proceso de elaboración⁴⁵. Por ejemplo, la prohibición del uso de ciertas armas o métodos de combate en los conflictos armados contenida en diversos tratados de derecho internacional humanitario.

39 Por ejemplo, ver *Plataforma continental* (Jamahiriya Árabe Libia/Malta), CIJ, Fallo, 03/06/1985, Opinión disidente del Juez Oda, parág. 30, en la cual se cita una obra de Shalowitz (*Shore and Sea Boundaries*) y un artículo de Hodgson y Cooper ("The Technical Delimitation of a Modern Equidistance Boundary") publicado en una revista jurídica.

40 A título de ejemplo, en el caso "Campo Algodonero", la Corte Interamericana de Derechos Humanos hizo referencia a numerosos estudios e informes sobre la situación de la mujer en Ciudad Juárez (México); *González y otras ("Campo Algodonero") c. México*, Corte IDH, Sentencia de excepción preliminar, fondo, reparaciones y costas, 16/11/2009, parág. 113 y ss.

41 Por ejemplo, *Suez, Sociedad General de Aguas de Barcelona S.A., y Vivendi Universal S.A. c. República Argentina* (caso CIADI Nº ARB/08/10) y *AWG Group c. República Argentina* (Arbitraje bajo la Regla de la ONUDMI), Decisión sobre Responsabilidad, 30/07/2010, parág. 188 (en el cual se cita la obra de Ian Brownlie, *Principles of Public International Law*).

42 Al respecto ver Nino, Carlos, *op. cit.*, p. 87.

43 *Ibid.*, p. 148.

44 Aunque con frecuencia se haga referencia indistintamente a las normas jurídicas y a las reglas de derecho, algunos juristas –como Ronald Dworkin y Robert Alexy– distinguen entre normas que son "principios" y normas que son "reglas". En este sentido, las reglas son consideradas como la concreción de un principio más general. Para una discusión sobre esta teoría ver Cianciardo, Juan, "Principios y reglas: una aproximación desde los criterios de distinción", *Boletín Mexicano de Derecho Comparado*, n.º 108 (2003), pp. 891-908. A título de ejemplo, en el marco de la Convención Americana de Derechos Humanos (1969), Cianciardo explica que la norma contenida en el artículo 5(1) –"Toda persona tiene derecho a que se respete su integridad física (...)– es un principio, mientras que la del artículo 8(2)(a) –"Durante el proceso, toda persona tiene derecho, en plena igualdad, a las siguientes garantías mínimas: (...)– es una regla (*ibid.*, pp. 894-895).

45 Una norma consuetudinaria general puede obligar a Estados que no participaron en su proceso de formación a través de la práctica, pero que tampoco se opusieron a ella. En el capítulo 12 de esta obra se analizará lo atinente a la aquiescencia en el derecho internacional, sus requisitos y efectos.

Cuando disponen obligaciones frente a toda la comunidad en su conjunto son normas (u obligaciones) *erga omnes*, de las que nos ocuparemos más abajo.

Las normas particulares son aquellas que vinculan solo a un número determinado de sujetos del derecho internacional (dos o más).

Las normas *bilaterales* obligan a dos sujetos; las *multilaterales*, en cambio, a más de dos. Por ejemplo, son bilaterales las normas previstas en un tratado de extradición celebrado entre dos Estados, que obliga a extraditar a los delincuentes comunes; son multilaterales las normas contenidas en la Convención de Ginebra sobre Plataforma Continental (1958).

Asimismo, las normas pueden ser *regionales* cuando vinculan a Estados o sujetos que pertenecen a una misma región geográfica, como las previstas en la Convención Americana sobre Derechos Humanos (1969).

En la práctica también se usan expresiones como "derecho internacional general", "derecho internacional particular" o "derecho (internacional) regional". En cuanto a la primera expresión, no siempre se utiliza como sinónimo de normas generales, sino que algunos autores la identifican exclusivamente con las normas generales consuetudinarias.

Según sus características, por un lado se distingue entre normas *sustantivas* (o *sustanciales*) y *procedimentales* (o *de procedimiento*) y, por el otro, entre normas *primarias* y *secundarias*.

Las normas *sustantivas* o *sustanciales* prescriben el comportamiento de los sujetos (por ejemplo, lo que se debe hacer o lo que está permitido o prohibido) con relación a cuestiones materiales del derecho internacional, por oposición a las *procedimentales* que establecen procedimientos o mecanismos formales a seguir en relación con el cumplimiento de las normas sustanciales. Por ejemplo, en el caso de las *Usinas de pasta de papel sobre el Río Uruguay* ante la Corte Internacional de Justicia, tanto la parte demandante como la propia Corte distinguieron entre las obligaciones sustanciales⁴⁶ y las obligaciones procedimentales⁴⁷ contraídas por la República Argentina y por la República Oriental del Uruguay en el Estatuto del Río Uruguay –tratado bilateral que regula la utilización del dicho río internacional–⁴⁸. Dentro de las obligaciones sustanciales se encontraba la de proteger y preservar el medio acuático y prevenir su contaminación (art. 41 del Estatuto del Río Uruguay), mientras que las obligaciones procedimentales consistían en cumplir con el mecanismo de información y consulta previa establecido en los artículos 7 a 12 del mencionado tratado para el caso de que se proyectase la realización de obras que pudiesen afectar el régimen del río o la calidad de sus aguas.

Sobre todo en el ámbito de la responsabilidad internacional, se distingue entre *normas primarias* y *normas secundarias*⁴⁹. Mientras las *primarias* son aquellas que prescriben el comportamiento de los sujetos (por ejemplo, lo que se debe hacer o lo que está permitido o prohibido) –como la prohibición de la tortura–, las normas *secundarias* determinan las consecuencias jurídicas del incumplimiento de una norma primaria –tal como el surgimiento de responsabilidad internacional y aplicación de sanciones o medidas de reparación⁵⁰.

Según la fuente creadora, se suele hacer referencia a las *normas convencionales* y a las *consuetudinarias*. Son *convencionales* aquellas que provienen de un tratado internacional –como los estándares de protección de las inversiones extranjeras contenidos en los tratados bilaterales de inversión–, mientras que las *consuetudinarias* nacen de la costumbre internacional –como las normas concernientes a la inmunidad de jurisdicción de los Estados–. Algunas normas pueden ser a la vez *convencionales* y *consuetudinarias*, por ejemplo, la que dispone la solución de las controversias por medios pacíficos, que es una norma consuetudinaria general contenida, además, en el artículo 2(3) de la Carta de las Naciones Unidas.

46 *Plantas de celulosa en el Río Uruguay* (Argentina c. Uruguay), CIJ, Fallo, 20/04/2010, parágs. 159-266.

47 *Ibid.*, parágs. 87-158.

48 Tal como se tratará en el capítulo 26 de esta obra.

49 Hart, Herbert L. A., *The Concept of Law*, Clarendon Press, Oxford, 1961, pp. 116-128. Hart también hablaba de las normas de cambio, es decir, aquellas que explicitan cómo pueden derogarse o modificarse las normas jurídicas de un ordenamiento.

50 Ver capítulos 15 a 17 de esta obra.

Según si admiten acuerdo en contrario, se distingue entre normas *dispositivas* por oposición a las *imperativas* o de *jus cogens*. Las normas *dispositivas* son aquellas normas generales o particulares que admiten acuerdo en contrario, es decir, dos o más Estados podrían acordar su modificación o derogación para sus relaciones mutuas. La mayoría de las normas del derecho internacional pertenecen a esta categoría. Puede citarse la regla del agotamiento de los recursos internos previo a acceder a un tribunal internacional. Las normas *imperativas* son aquellas normas generales que no admiten acuerdo en contrario y que solo pueden ser modificadas en el futuro por otras normas imperativas. Por ejemplo, la norma que prohíbe la comisión de actos de genocidio. En el próximo apartado analizaremos con más detalle esta última categoría de normas.

4.2. Normas imperativas (*jus cogens*)

La Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados (1969) es el primer instrumento internacional que define las normas imperativas, y lo hace en el contexto de la mención de una de las causales de nulidad de los tratados. En efecto, el artículo 53 de dicha Convención estipula lo siguiente:

Artículo 53 - Tratados que estén en oposición con una norma imperativa de derecho internacional (*jus cogens*)

Es nulo todo tratado que, en el momento de su celebración, esté en oposición con una norma imperativa de derecho internacional general. Para los efectos de la presente Convención, una norma imperativa de derecho internacional general es una norma aceptada y reconocida por la comunidad internacional de Estados en su conjunto como norma que no admite acuerdo en contrario y que sólo puede ser modificada por una norma ulterior de derecho internacional general que tenga el mismo carácter.

La Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados entre Estados y Organizaciones Internacionales o entre Organizaciones Internacionales (1986) reproduce idéntica definición en el homónimo artículo 53.

Si bien esta definición fue elaborada a los efectos de dichas convenciones, en general se la considera una definición aceptable, más allá de sus ambigüedades y de las críticas que ha recibido. Veamos las características o presupuestos de las normas imperativas que surgen de esta definición.

a) Se trata de una norma de derecho internacional general

A la luz de este enunciado todas las normas imperativas de derecho internacional son normas generales, pero no a la inversa, puesto que no todas las normas generales son imperativas —de hecho la mayoría no lo son—⁵¹.

Respecto a la fuente, cabe preguntarse si provienen del derecho internacional consuetudinario o si pueden ser pactadas convencionalmente por los Estados. Algunos autores interpretan que la referencia al derecho internacional general significa exclusivamente derecho internacional consuetudinario; sin embargo, otros consideran que esto contradice la práctica y

51 Cabe aclarar que no han faltado autores que se preguntaron si podía existir una norma imperativa particular o regional, es decir, que un grupo de Estados pacten una obligación inderogable entre ellos. Es importante tener presente que la finalidad de las normas imperativas es proteger valores universales, que prácticamente todos los Estados consideran que deben ser protegidos, evitando que dos o más Estados en particular atenten contra ellos. No tendría ningún sentido una norma imperativa particular que siempre pudiera ser modificada o dejada sin efecto por esos mismos Estados en el futuro, ya que una norma imperativa puede ser modificada por otra norma imperativa. Por su parte, Gómez Robledo considera que "por lo menos, dentro del régimen de la Convención de Viena, no hay lugar por ahora para un *jus cogens* particular o regional"; Gómez Robledo, Antonio, *El jus cogens internacional. Estudio histórico-crítico*, Universidad Nacional Autónoma de México, México, 2003, p. 78.

reafirman el carácter "consensual" de la noción de *jus cogens*⁵². Lo cierto es que la mayoría de las normas imperativas de derecho internacional son normas consuetudinarias codificadas en tratados internacionales.

b) Es una norma aceptada y reconocida por la comunidad internacional de Estados en su conjunto

Una pregunta corriente consiste en determinar si se requiere unanimidad o qué mayoría de Estados debe existir para que se acepte y reconozca que una norma es imperativa, es decir, qué cantidad de Estados califica de "comunidad internacional de Estados en su conjunto".

Al respecto, el Comité de Redacción de la Convención de Viena de 1969 opinó que un solo Estado así como un grupo muy pequeño de Estados no podía afectar la formación de una norma imperativa⁵³. En general se alude a la necesidad de aceptación por parte de un considerable número de Estados. Sin embargo, algunos doctrinarios estiman que la expresión "en su conjunto" no puede reducirse a una cuestión meramente cuantitativa. Resulta necesario que en esa mayoría estén representados Estados de diferentes continentes, con diferentes sistemas políticos, sociales y económicos, y con distintos grados de desarrollo⁵⁴.

c) Es una norma que no admite acuerdo en contrario

La norma imperativa no admite acuerdo en contrario, ni *pasado ni futuro*. Por ejemplo, si aceptamos que la prohibición de la esclavitud y la piratería son normas imperativas, a partir del momento en que ello ocurra (desde que se reconozca el carácter imperativo), no pueden seguir en vigencia acuerdos celebrados en el pasado sobre compraventa de esclavos o establecimiento de patentes de corso, así como tampoco pueden aceptarse como válidos futuros tratados con dicho objeto.

Cabe hacer una aclaración respecto de la terminología empleada por la Convención de Viena en su texto en español —que dispone que "no admite acuerdo en contrario"—, a diferencia de los textos en inglés y en francés —en los cuales se estipula que la norma no permite "derogación" alguna—, si bien todos ellos son igualmente auténticos. Como señala Gómez Robledo, el texto en español "no define la norma imperativa por su inderogabilidad, sino simplemente por el hecho de no admitir acuerdo en contrario" y, citando al profesor Miaja de la Muela, expresa que la esencia del *jus cogens* "no está en la inderogabilidad de la norma sino en la imposibilidad de que los sujetos de la norma se sustraigan en ningún caso a su aplicación"⁵⁵.

d) Es una norma que solo puede ser modificada por una norma imperativa posterior

Con respecto a este punto, la pregunta es si una norma imperativa puede ser derogada por completo por otra norma imperativa, o si solo puede ser modificada, siguiendo la letra expresa del artículo 53 de las convenciones de Viena de 1969 y 1986.

Gómez Robledo afirma que "la norma en sí misma [...], ya sea dispositiva o imperativa, es siempre derogable, con tal que lo hagan los mismos sujetos que la crearon"⁵⁶.

Ante la ausencia de jurisprudencia internacional sobre normas de *jus cogens* al momento de la negociación de la Convención de Viena de 1969, mucho se ha discutido sobre si esta categoría de normas era una noción nueva o ya formaba parte del derecho internacional consuetudinario. En efecto, no había referencias en la jurisprudencia de la CIJ o de la CPJI, sino tan solo menciones en algunas opiniones separadas o disidentes de los jueces⁵⁷. Alexidze sostiene

52 Alexidze, Levan, "Legal nature of *jus cogens* in contemporary international law", en *R.C.A.D.I.*, vol. 172 (1981-III), p. 256.

53 *Ibid.*

54 *Ibid.*, pp. 257-258.

55 Gómez Robledo, Antonio, *op. cit.*, p. 75.

56 *Ibid.*, p. 75.

57 Cfr. Alexidze, Levan, *op. cit.*, p. 228.

que la ausencia de casos no puede ser evidencia de la inexistencia de la institución misma⁵⁸ y muestra que "Mientras en la teoría del derecho internacional el término *jus cogens* ha aparecido más bien recientemente (desde comienzos de la década de 1930), por siglos ha existido en la doctrina del derecho internacional una idea de reglas de derecho absolutamente compulsivas que servían de criterio para determinar la validez de los tratados internacionales"⁵⁹. Si bien los doctrinarios no aportaban demasiados detalles, y se aludía a estos principios o normas con distintas denominaciones (por ejemplo, "derecho necesario"), el mencionado autor considera que tales disposiciones nacieron más bien por analogía a la noción de orden público existente en todos los ordenamientos internos de los Estados⁶⁰.

Pese a que en teoría se ha definido qué es una norma imperativa, en la práctica resulta sumamente difícil identificar cuáles son en concreto todas las normas imperativas. Así, los académicos han elaborado distintos métodos o criterios para resolver la cuestión, pero a ciencia cierta ninguno de ellos es conclusivo o está libre de críticas.

En general, los autores incluyen, entre otros, las siguientes normas como ejemplos de *jus cogens*:

- los principios de la solución pacífica de controversias; la prohibición de la amenaza o el uso de la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de los Estados; la igualdad de derechos y la libre determinación de los pueblos;
- la prohibición de graves violaciones a los derechos humanos, como la esclavitud, el genocidio, el *apartheid*, los crímenes de lesa humanidad, los crímenes de guerra.

En la actualidad, la Corte Internacional de Justicia se muestra muy prudente, como advierten los internacionalistas⁶¹, por lo que es también objeto de críticas, y evita tener que calificar como normas imperativas a algunas de las normas invocadas por los Estados, tanto en los procedimientos contenciosos como en los consultivos. Así, en diversas ocasiones ha utilizado, en lugar de "norma imperativa", la expresión "principio intransgredible" para calificar a normas o principios determinados –tales como los principios del derecho internacional humanitario⁶²– o los términos "obligaciones *erga omnes*" para hacer alusión a la autodeterminación de los pueblos⁶³.

En el caso del *Personal diplomático y consular de los EE.UU. en Teherán*, la CIJ fue más allá y sostuvo que, aunque ningún Estado estaba obligado a mantener relaciones diplomáticas o consulares con otro, no se podía evitar reconocer las obligaciones imperativas inherentes a ellas, codificadas en las Convenciones de Viena de 1961 y 1963⁶⁴.

Las normas imperativas traen aparejada una serie de consecuencias. En el marco del derecho de los tratados, como se verá en el capítulo 8 de esta obra, la oposición de un nuevo tratado a una norma imperativa ya existente es considerada causal de nulidad del tratado (*jus cogens* existente), mientras que el surgimiento de una nueva norma imperativa acarrea la terminación de todo tratado previamente celebrado que se oponga a ella (*jus cogens* emergente). Ello en virtud de lo establecido en los artículos 53 y 64 de las Convenciones de Viena de 1969 y 1986. Por su parte, el artículo 71 dispone cuáles son las consecuencias de la nulidad

de un tratado que esté en oposición con una norma imperativa⁶⁵. Si surgiera una controversia entre los Estados contratantes por la interpretación o aplicación de los artículos 53 o 64, ambos tratados prevén en el artículo 66(2) que dicha controversia pueda ser sometida de manera compulsiva a la Corte Internacional de Justicia, lo que no ocurre con la interpretación o aplicación de otros artículos de tales convenciones. En particular, la Convención de Viena de 1986 prevé la posibilidad de solicitar una opinión consultiva a la CIJ cuando la controversia involucre a una organización internacional⁶⁶. En este último supuesto, las partes contratantes aceptan de antemano que la opinión consultiva tendrá carácter vinculante⁶⁷.

En el marco de la responsabilidad internacional del Estado, la Comisión de Derecho Internacional (CDI) ha previsto en su Proyecto de artículos sobre responsabilidad internacional del Estado por hechos internacionalmente ilícitos algunas disposiciones con el fin de proteger el cumplimiento de normas imperativas. Así, los artículos 26 y 50 establecen:

Artículo 26 - Cumplimiento de normas imperativas

Ninguna disposición del presente capítulo excluirá la ilicitud de cualquier hecho de un Estado que no esté de conformidad con una obligación que emana de una norma imperativa de derecho internacional general.

Artículo 50 - Obligaciones que no pueden ser afectadas por las contramedidas

1. Las contramedidas no afectarán:

- a) La obligación de abstenerse de recurrir a la amenaza o al uso de la fuerza, como está enunciada en la Carta de las Naciones Unidas;
- b) Las obligaciones establecidas para la protección de los derechos humanos fundamentales;
- c) Las obligaciones de carácter humanitario que prohíben las represalias;
- d) Otras obligaciones que emanan de normas imperativas del derecho internacional general.

[...]

Asimismo, el capítulo III del Proyecto de la CDI contempla el supuesto de violaciones graves (incumplimientos flagrantes o sistemáticos) de obligaciones emanadas de normas imperativas del derecho internacional general, estableciendo en el artículo 41 consecuencias particulares que involucran a todos los Estados de la comunidad internacional (no solo al Estado que violó la norma imperativa), tales como el deber de cooperar para poner fin a la violación, no reconocer la licitud de una situación creada por dicha violación y no prestar ayuda o asistencia para mantener esa situación. Como se verá en el capítulo 15 de esta obra, además de las consecuencias normales que produce la responsabilidad internacional en cabeza del Estado responsable de la violación, en el supuesto de violación grave de una norma imperativa se generarán consecuencias adicionales para todos los Estados. La CIJ ha tenido ocasión de confirmar esto

58 Ibid., p. 232.

59 Ibid., p. 228 (traducción libre).

60 Ibid., p. 238.

61 Tavernier, Paul, "L'identification des règles fondamentales, un problème résolu?", en *The Fundamental Rules of the International Legal Order. Jus Cogens and Obligations Erga Omnes*, Tomuschat, Christian y Thouvenin, Jean-Marc (eds.), Nijhoff, Londen/Boston, 2008, p. 6.

62 Legality of the threat or use of nuclear arms, CIJ, Opinión Consultiva, 08/07/1996, ICJ Reports 1996, p. 287.

63 Consecuencias jurídicas de la construcción de un muro en el territorio palestino ocupado, doc. cit., parág. 155.

64 Personal diplomático y consular de los EE.UU. en Teherán (EE.UU. c. Irán), CIJ, Solicitud de medidas provisionales, Providencia, 16/12/1979, ICJ Reports 1979, p. 20, parág. 41.

65 El artículo 71 de la Convención de Viena de 1969 estipula:

"1. Cuando un tratado sea nulo en virtud del artículo 53, las demás Partes deberán:

- a) Eliminar en lo posible las consecuencias de todo acto que se haya ejecutado basándose en una disposición que esté en oposición con la norma imperativa de derecho internacional general; y
- b) Ajustar sus relaciones mutuas a la norma imperativa de derecho internacional general.

2. Cuando un tratado se convierta en nulo y termine en virtud del artículo 64, la terminación del tratado:

- a) Eximirá a las Partes de toda obligación de seguir cumpliendo el tratado.
- b) No afectará a ningún derecho, obligación o situación jurídica de las Partes creados por la ejecución del tratado antes de su terminación; sin embargo, esos derechos, obligaciones o situaciones podrán en adelante mantenerse únicamente en la medida en que su mantenimiento no esté por sí mismo en oposición con la nueva norma imperativa de derecho internacional general".

66 Convención de Viena de 1986, artículo 66(2)(b).

67 Ibid., artículo 66(2)(3).

en la opinión consultiva sobre las *Consecuencias jurídicas de la construcción de un muro en el territorio palestino ocupado*⁶⁸.

4.3. Normas (u obligaciones) *erga omnes*

En el célebre caso de la *Barcelona Traction*, la Corte Internacional de Justicia sostuvo:

33. [...] Una distinción esencial en particular debe ser establecida entre las obligaciones de los Estados hacia la Comunidad internacional en su conjunto y aquellas que nacen vis-à-vis otro Estado en el marco de la protección diplomática. Por su propia naturaleza, las primeras son de interés para todos los Estados. Habida cuenta de la importancia de los derechos involucrados, puede entenderse que todos los Estados tienen un interés jurídico en su protección; ellas son obligaciones *erga omnes*.

34. Tales obligaciones derivan, por ejemplo, en derecho internacional contemporáneo, de la proscripción de actos de agresión, y de genocidio, así como también de los principios y reglas concernientes a los derechos básicos de la persona humana, incluida la protección de la esclavitud y la discriminación racial. Algunos de los derechos de protección correspondientes forman parte del cuerpo del derecho internacional general [...]; otros están estipulados en instrumentos internacionales de carácter universal o cuasi-universal.⁶⁹

En estos párrafos, que han suscitado numerosos comentarios por parte de académicos, la CIJ estaba haciendo referencia a las obligaciones *erga omnes*, es decir, aquellas que el Estado asume frente a la comunidad internacional en su conjunto.

Algunos autores hablan directamente de *erga omnes*, mientras que otros, como la CIJ en el caso de la *Barcelona Traction*, utilizan la expresión "obligaciones *erga omnes*"⁷⁰, focalizándose más bien en una parte de su contenido, ya que, en realidad, las obligaciones –así como los derechos– forman parte de una norma⁷¹. En ocasiones también se hace referencia a "normas *erga omnes*"⁷² o a "derechos *erga omnes*"⁷³.

En general, no hay acuerdo entre los juristas respecto del concepto exacto de *erga omnes* ni de sus consecuencias⁷⁴. Por lo tanto, tampoco ha sido posible enumerar de manera exhaustiva a todas las normas *erga omnes*.

En cuanto a las consecuencias, algunos autores ponen énfasis en la posibilidad de que los Estados –aunque no sea el Estado directamente lesionado– adopten contramedidas contra el Estado responsable frente a la violación de una obligación *erga omnes*⁷⁵.

68 *Consecuencias jurídicas de la construcción de un muro en el territorio palestino ocupado*, doc. cit., parág. 163. Ver también Barboza, Julio, "La responsabilidad internacional y la opinión consultiva de la CIJ sobre el muro en Cisjordania", en *La Corte Internacional de Justicia y el Derecho Internacional. Temas relacionados con la Opinión Consultiva sobre la Construcción del Muro*, Barboza, Julio (coord.), Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales, Buenos Aires, 2005, pp. 35-49.

69 *Barcelona Traction, Light and Power Company Ltd* (Bélgica c. España), CIJ, Fallo, 05/02/1970, *ICJ Reports* 1970, p. 32, párrs. 33 y 34 (traducción libre; citas omitidas).

70 Tams, Christian J., *Enforcing Obligations Erga Omnes in International Law*, Cambridge University Press, Cambridge, 2005; Tomuschat, Christian y Thouvenin, Jean-Marc (eds.), *op. cit.*, entre muchos otros.

71 Giorgio Gaja se refiere tanto a derechos como a obligaciones *erga omnes* en "Les obligations et les droits *erga omnes* en droit international. Obligations and Rights *Erga Omnes* in International Law", *Annuaire de l'Institut de droit international*, vol. 71-II, n.º 2 (2006), pp. 81-136.

72 Delbrück, Jost, "Laws in the public interest: some observations on the foundations and identification of *Erga Omnes* norms in international law", en *Liber amicorum Günter Jaenicke*, Götz, Volkmar; Selmer, Peter; Wolfrum, Rüdiger; Philipp, Christiane y Jaenicke, Günther (eds.), Springer, Berlín, 1998, pp. 17-36.

73 *Timor Oriental* (Portugal c. Australia), CIJ, Fallo, 30/06/1995, *ICJ Reports* 1995, p. 102, parág. 29.

74 Tams, Christian J., *op. cit.*, p. 4.

75 Frowein, Jochen A., "Obligations *erga omnes*" (2009), en *Max Planck Encyclopedia of Public International Law*, <http://www.mpepil.com>, párr. 12.

Sin duda, otra de las consecuencias es la posibilidad de cualquier Estado de reclamar por el incumplimiento de tales obligaciones⁷⁶.

En la opinión consultiva sobre la presencia de Sudáfrica en Namibia, la CIJ expresó que "la terminación del mandato y la declaración de la ilegalidad de la presencia de Sudáfrica en Namibia son oponibles a todos los Estados en el sentido de hacer ilegal *erga omnes* una situación que se mantiene en violación del derecho internacional"⁷⁷.

En el caso *Timor Oriental*, Portugal adujo que los derechos que alegaba que habían sido violados por Australia eran *erga omnes*, refiriéndose fundamentalmente al principio de la autodeterminación de los pueblos –en particular, del pueblo de Timor–; en consecuencia, Portugal podía, individualmente, requerir su respeto. La Corte sostuvo que era irreproachable el carácter *erga omnes* de aquel principio esencial del derecho internacional contemporáneo⁷⁸. Sin embargo, también sostuvo:

[...] el carácter *erga omnes* de una norma y la regla del consentimiento a la jurisdicción son dos cosas diferentes. Cualquiera sea la naturaleza de las obligaciones invocadas, la Corte no puede expedirse sobre la licitud de la conducta de un Estado si su fallo podría implicar una evaluación de la licitud de la conducta de otro Estado que no es parte en el caso. Cuando ello ocurre, la Corte no puede actuar, ni siquiera si el derecho en cuestión es un derecho *erga omnes*⁷⁹.

Como el alegado incumplimiento de la norma *erga omnes* derivaba de un tratado celebrado entre Australia e Indonesia, al no haber esta última aceptado la jurisdicción de la CIJ, la Corte declaró que no poseía jurisdicción para entender en la controversia.

De modo que, del carácter *erga omnes* de una norma se deriva que cualquier Estado podría reclamar por su incumplimiento, por ejemplo, ante un tribunal internacional, pero siempre y cuando todos los Estados involucrados en la controversia hayan aceptado la jurisdicción de dicho tribunal.

En el asunto concerniente a la Aplicación de la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio, la Corte sostuvo que "los derechos y las obligaciones consagrados en la Convención eran derechos y obligaciones *erga omnes*", por lo tanto, su competencia temporal en la controversia no se limitaba a la fecha a partir de la cual las partes estaban vinculadas por la Convención de genocidio⁸⁰.

En la ya mencionada opinión consultiva sobre las *Consecuencias jurídicas de la construcción de un muro en el territorio palestino ocupado*, la CIJ afirmó que entre las obligaciones violadas por Israel se encontraban algunas *erga omnes*, como el derecho del pueblo palestino a la libre determinación y ciertas obligaciones de derecho internacional humanitario⁸¹. La Corte recordó que, en su opinión consultiva sobre la Legalidad del uso o la amenaza de armas nucleares, había afirmado que había un gran número de reglas aplicables en caso de conflicto armado que eran tan fundamentales para el respeto de la persona y constituían principios elementales de humanidad que todos los Estados debían cumplir, hubieran o no ratificado los convenios que las estatufan, porque constituían "principios intransgredibles de derecho internacional

76 Ver Gaja, Giorgio, "Do States have a duty to ensure compliance with obligations *erga omnes* by other States?", en *International Responsibility Today: Essays in Memory of Oscar Schachter*, Ragazzi, Maurizio (ed.), Martinus Nijhoff Publishers, Leiden/Boston, 2005, pp. 31-36.

77 *Consecuencias jurídicas que tiene para los Estados la continuación de la presencia de Sudáfrica en Namibia (África Sudoccidental)*, no obstante lo dispuesto en la Resolución 276 (1970) del Consejo de Seguridad, CIJ, Opinión Consultiva, 21/06/1971, *ICJ Reports* 1971, p. 66, parág. 126 (traducción libre).

78 *Timor Oriental*, doc. cit., p. 102, parág. 28.

79 *Ibid.* (traducción libre).

80 *Aplicación de la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio* (Bosnia-Herzegovina c. Yugoslavia –Serbia y Montenegro–), CIJ, Fallo sobre excepciones preliminares, 11/07/1996, *ICJ Reports* 1996, p. 616, parág. 31.

81 *Consecuencias jurídicas de la construcción de un muro en el territorio palestino ocupado*, doc. cit., párrs. 156-158.

consuetudinario⁸². Según la Corte, tales reglas incorporan obligaciones que son esencialmente de carácter *erga omnes*⁸³.

Respecto de las consecuencias jurídicas de estas obligaciones *erga omnes*, la Corte también expresó:

159. Habida cuenta del carácter y la importancia de los derechos y obligaciones involucrados, la Corte opina que todos los Estados tienen la obligación de no reconocer la situación ilegal resultante de la construcción del muro en el territorio palestino ocupado, incluida Jerusalén oriental y sus alrededores. Asimismo tienen la obligación de no prestar ayuda ni asistencia para el mantenimiento de la situación creada por tal construcción. Incumbe también a todos los Estados, dentro del respeto por la Carta de las Naciones Unidas y el derecho internacional, velar por que se ponga fin a cualquier impedimento, resultante de la construcción del muro, para el ejercicio por el pueblo palestino de su derecho a la libre determinación. Además, todos los Estados partes en el Convenio de Ginebra relativo a la protección debida a las personas civiles en tiempo de guerra de 12 de agosto de 1949, tienen la obligación, dentro del respeto por la Carta de las Naciones Unidas y el derecho internacional, de hacer que Israel respete el derecho internacional humanitario incorporado en dicho Convenio.⁸⁴

En cuanto a la relación entre las normas u obligaciones *erga omnes* y las normas imperativas, podría decirse que toda norma imperativa constituye una obligación *erga omnes*, pero no a la inversa, puesto que no todas las obligaciones *erga omnes* son normas imperativas.

⁸² Legalidad del uso o la amenaza de armas nucleares, doc. cit., p. 257, parág. 79.

⁸³ Consecuencias jurídicas de la construcción de un muro en el territorio palestino ocupado, doc. cit., parág. 157.

⁸⁴ *Ibid.*, parág. 159.

CAPÍTULO 5

LA COSTUMBRE INTERNACIONAL

Paula M. Vernet

1: Concepto y elementos constitutivos

La costumbre internacional es uno de los modos de formación del derecho internacional. Se denomina costumbre no solo al proceso de creación de normas, sino también al resultado de ese proceso¹. Se la define como la práctica común, constante y uniforme generalmente aceptada como derecho².

El artículo 38 del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia —que, como hemos visto en el capítulo 4, es considerado por la doctrina como el que enumera las fuentes del derecho internacional—, en el inciso 1(b), se refiere a “la costumbre internacional como prueba de una práctica generalmente aceptada como derecho”. Esta expresión ha sido considerada como poco feliz o al menos curiosa, dado que es la práctica lo que evidencia la formación de la costumbre y no a la inversa. Sin embargo, el orden de los términos no hace gran diferencia, lo que es claro es que la definición de costumbre comprende dos elementos: la práctica y la aceptación como derecho³.

La costumbre es el resultado de un proceso que muchos describen como “misterioso”, a través del cual determinados hechos adquieren carácter legal, creando derechos y obligaciones para los sujetos de derecho internacional. Existen distintos modos de concebir la costumbre internacional, que dependen en gran medida de la teoría acerca del derecho en general. La principal discusión en la doctrina radica en si existe o no una norma de derecho que es fuente de validez de la costumbre.

Entre los que entienden que esa regla existe se distinguen dos grupos: aquellos, como Anzilotti y Triepel, que sostienen que la costumbre no es otra cosa que un tratado tácito y, por lo tanto, su fuente de validez es *pacta sunt servanda*, y otros que, como Kelsen, al no encontrar una norma en el derecho positivo para dar fundamento a la costumbre, buscan el fundamento en una norma hipotética fundamental (*Grundnorm*), *consuetudo est servanda*, que tiene por función instituir a la costumbre en un método creador de derecho y la concibe como una fuente autónoma de derecho internacional⁴.

¹ Treves, Tullio, “Customary International Law” (2009), en *Max Planck Encyclopedia of Public International Law*, <http://www.mpepil.com>, párr. 1; ver también Moncayo, Guillermo; Vinuesa, Raúl y Quiñéres Posse, Hortensia D.T., *Derecho Internacional Público*, Zavalla, Buenos Aires, 6.ª reimp., 1999, t. 1, p. 82.

² Ver casos de la *Plataforma continental del Mar del Norte* (República Federal de Alemania/Dinamarca; República Federal de Alemania/Paises Bajos), CIJ, Fallo, 20/02/1989, ICJ Reports 1989, p. 45, parág. 77-78; *Plataforma continental (Jamahiriya Árabe Libia/Malta)*, CIJ, Fallo, 02/06/1985, pp. 20-50, parág. 27; *Actividades militares y paramilitares en y contra Nicaragua* (Nicaragua c. EE.UU.), CIJ, Fallo (Rendó), 27/06/1986, ICJ Reports 1986, pp. 97, 108-109; *Legalidad de la amenaza o el uso de armas nucleares*, CIJ, Opinión Consultiva, 08/07/1996, ICJ Reports 1996, p. 253.

³ Damrosch, Lori Fisler, et al., *International Law, Cases and Materials*, Thomson West, St. Paul, 5.ª edic., 2009, p. 69.

⁴ Treves, Tullio, op. cit., párr. 4 y ss.

Por otro lado están aquellos, como Ago y Barberis, que entienden que la costumbre no sería creada mediante un procedimiento regulado jurídicamente, sino que se presentaría de manera espontánea, es decir, como una manifestación no organizada anticipadamente. Para ellos las normas consuetudinarias internacionales no son creadas por una fuente de derecho⁵. Su existencia dependerá de que puedan ser comprobadas de manera empírica y tengan efectividad en la comunidad internacional.

Debemos preguntarnos, entonces, cuáles son los elementos que deben comprobarse empíricamente para identificar la existencia de la costumbre. La mayoría de la doctrina entiende que, **en la formación de la norma consuetudinaria, como dijimos al comienzo, intervienen dos elementos, uno material, la práctica, y uno psicológico, la convicción de que tal conducta obliga en derecho**, a la que se denomina *opinio iuris sive necessitatis*.

1.1. La práctica

La costumbre internacional tiene la particularidad de conformarse por una conducta; no está expresada en lenguaje natural, es un comportamiento o una serie de comportamientos que en general se reiteran en el tiempo y, a través de su repetición, junto con el elemento psicológico, dan lugar a la formación de una norma jurídica.

Tradicionalmente, se ha otorgado más énfasis a la conducta, el elemento material de la costumbre, que al elemento subjetivo. Esto resulta comprensible si tenemos en cuenta que la convicción o los deseos de un Estado son más difíciles de identificar que su conducta, que es, en general —por su naturaleza—, objetiva y públicamente verificable. Con la aparición de distintos foros multilaterales, en especial la Organización de las Naciones Unidas, podría tal vez afirmarse que la situación ha cambiado⁶, pero trataremos esta cuestión más adelante en el apartado 7.

Con relación al elemento material, la primera pregunta que debemos hacernos es qué es lo que se considera práctica. En primer lugar, los actos que constituyen la práctica deben ser conductas humanas, el derecho no le da relevancia a los hechos de la naturaleza para la creación de normas, y deben tratarse de actos vinculados con las relaciones internacionales, **la práctica exclusivamente interna no puede dar lugar a una costumbre internacional**⁷.

La doctrina no es pacífica sobre si deben considerarse solo los actos de los sujetos o también sus declaraciones. Mientras que para algunos estas últimas son una forma de práctica, para otros se trataría de una manifestación del elemento psicológico, y tener en cuenta las declaraciones como práctica podría llevar a que un mismo acto pueda ser considerado a la vez como elemento material y elemento subjetivo⁸. Suponer esto podría dar lugar a malinterpretar la cantidad de práctica y la verdadera "densidad" necesaria para la formación de la costumbre⁹.

Asimismo, cabe preguntarse cuál es el rol de las omisiones a la hora de analizar la práctica. **La mayoría de la doctrina las admite como práctica**. En el caso *Lotus*, Francia invocó una regla consuetudinaria según la cual, en caso de abordaje en alta mar, la jurisdicción penal quedaba reservada a los tribunales del Estado de la bandera del buque, y para probarlo recurrió a una serie de abstenciones. La Corte sostuvo que, aun cuando las decisiones judiciales presentadas fueran suficientes para probar las alegaciones de Francia, solo demostraría que los Estados se abstuvieron, en la práctica, de iniciar procedimientos penales, y no que reconocieron no estar obligados a hacerlo. Pues únicamente podría hablarse de una costumbre si esa

⁵ Barberis, Julio A., *Formación del derecho internacional*, Ábaco de Rodolfo de Palma, Buenos Aires, 1994, pp. 74-78.

⁶ Mendelson, Maurice H., "Formation of Customary International Law", *R.C.A.D.I.*, vol. 272 (1998), p. 187.

⁷ Barberis, Julio A., *op. cit.*, p. 84.

⁸ Kammerhofer, Jörg, "Uncertainty in the Formal Sources of International Law: Customary International Law and Some of Its Problems", *E.J.I.L.*, vol. 15 (2004), p. 526. Para los voluntaristas ambas formas de conducta son manifestación de la voluntad del Estado, mientras que, para aquellos que le dan importancia a la creencia de estar a derecho, las declaraciones serían manifestaciones de esta creencia y los actos físicos serían tenidos en cuenta como elemento material.

⁹ Mendelson, Maurice H., *op. cit.*, p. 207.

abstención estuviera basada en la conciencia de tener la obligación de abstenerse¹⁰. La Corte no rechazó el argumento porque las omisiones no pudieran contarse como práctica, sino porque en este caso las abstenciones eran de carácter ambiguo, pues podían deberse a numerosos motivos¹¹. Sin embargo, no hay duda de que determinadas omisiones pueden ser consideradas como práctica estatal¹².

La doctrina y la jurisprudencia han referido que la conducta debe ser general, constante y uniforme, aunque en definitiva en la actualidad la práctica muchas veces suele carecer de alguno o hasta de todos esos atributos. Tradicionalmente, se ha requerido que el comportamiento adquiriera cierta generalidad y que se reiterara en el tiempo a fin de que pueda dar lugar a una costumbre internacional. Para analizar acabadamente el elemento objetivo debemos examinar, en primer lugar, la práctica de quiénes, es decir de qué sujetos, resulta relevante para la formación de la costumbre y, por otra parte, los elementos de uniformidad, transcurso de tiempo y generalidad que debe alcanzar la conducta para convertirse en una costumbre internacional.

1.1.1. Los autores de la práctica

En general, en el derecho internacional se hace referencia a la práctica de los Estados. Como el Estado es una persona jurídica que actúa a través de sus órganos, cabe preguntarse, entonces, la conducta de qué órganos, instituciones o personas físicas que actúen en nombre del Estado pueden o deben tenerse en cuenta para configurar el elemento material de la costumbre.

Algunos autores han afirmado que solo debe considerarse la conducta de aquellos órganos que, de acuerdo con el derecho interno del Estado, tienen capacidad de obligarlo internacionalmente, circunscribiéndolo a quienes llevan adelante las relaciones internacionales: jefe de Estado, jefe de gobierno, ministro de relaciones exteriores y el cuerpo diplomático¹³; sin embargo, esta postura es muy restrictiva. Otros autores entienden que la conducta de aquellos que resulta atribuible al Estado para generar responsabilidad internacional¹⁴ sería también la que debe tenerse en cuenta a la hora de identificar la práctica del Estado.

Por otra parte, no solo la práctica de los Estados contribuye al desarrollo de normas consuetudinarias, la práctica de las organizaciones internacionales también puede generarlas. Por ejemplo, en la Opinión Consultiva sobre *Reservas a la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio*¹⁵ la CIJ, para determinar la costumbre relativa a las reservas a los tratados, tuvo en cuenta la práctica llevada a cabo por el secretario general de las Naciones Unidas en su carácter de depositario de tratados multilaterales¹⁶.

La práctica de las organizaciones internacionales es de gran importancia para establecer la existencia del elemento material. En este sentido, algunos se refieren a las resoluciones que adoptan las organizaciones, en especial las de la Asamblea General de las Naciones Unidas, pero, en realidad, la adopción de tales instrumentos sería más útil para establecer la conducta

¹⁰ *S.S. Lotus* (Francia c. Turquía), CRII, Fallo, 07/09/1927, *PCIJ Serie A*, n.º 10, p. 28.

¹¹ Mendelson, Maurice H., *op. cit.* p. 208. Otro ejemplo de un comportamiento ambiguo puede encontrarse en la Opinión Consultiva sobre la *Legalidad de la amenaza o el uso de armas nucleares* (doc. cit.), en la que la CIJ rechaza el argumento respecto a que, porque los Estados que poseen armas nucleares se han abstenido de utilizarlas desde 1945, han aceptado la obligación de nunca más utilizarlas.

¹² Para Barberis esta cuestión se trata solo de un pseudoproblema que se da en el plano del lenguaje y no en el de la realidad, porque un hecho no es ni positivo ni negativo; lo que tiene este sentido es la proposición que utilizamos para describir el hecho. Para este autor, Francia podría haber probado la costumbre mediante hechos positivos recurriendo a la práctica de los tribunales del Estado del pabellón que de modo constante se hubieran atribuido competencia penal. A Mendelson no le parece convincente esta explicación, pues afirma que la jurisdicción puede ser concurrente, y demostrar que el Estado del pabellón ejerció jurisdicción no habría probado que tenían el derecho exclusivo de hacerlo. Por lo tanto, Francia necesitaba recurrir a las abstenciones.

¹³ Tal el caso de Strupp y Anzilotti, citados por Mendelson, Maurice H., *op. cit.*, p. 198. Estos autores estarían influenciados por la concepción de la costumbre como tratado tácito.

¹⁴ Ver artículos 4 a 11 del anexo I a la Resolución 58/83 de la Asamblea General.

¹⁵ *Reservas a la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio*, CIJ, Opinión Consultiva, 28/11/1951, parágrafo 25.

¹⁶ Akehurst, Michael, "Custom as a Source of International Law", *B.Y.I.L.*, vol. 47 (1974-1975), p. 11.

de los Estados miembros que de la propia Organización¹⁷; los Estados, al votar, se comportan de una manera determinada o bien muestran su actitud con relación a la norma en cuestión.

Es necesario, entonces, realizar una distinción entre la práctica interna de la organización, es decir, la puramente institucional, que daría lugar a una norma consuetudinaria dentro del ordenamiento interno de la propia organización¹⁸ y la contribución de las organizaciones a la formación de normas generales de costumbre internacional aplicables fuera del marco de la organización. Está claro que, en ambos casos, las resoluciones adoptadas por los órganos de la organización son de relevancia en el proceso consuetudinario, pero desempeñan un papel diferente. En cuanto al derecho de la propia organización, las resoluciones serían parte de la práctica. Sin embargo, cuando se refiere a la formación de costumbre internacional general, las cosas serían distintas; para estos casos se ha sugerido que las resoluciones servirían más bien para probar la *opinio iuris* que como manifestación de la práctica¹⁹.

En un sentido amplio, la conducta de otras entidades como organizaciones no gubernamentales, empresas multinacionales o nacionales e incluso individuos puede contribuir a la formación de la costumbre. Estas entidades pueden ejercer presión o hacer *lobby* ante los Estados o las organizaciones internacionales para que realicen determinada conducta. Sin embargo, se trata de una contribución indirecta; en definitiva será la conducta de los órganos del Estado la que será tenida en cuenta para determinar si se ha configurado o modificado una costumbre²⁰.

No obstante, en algunos casos puede darse que la actividad de estas entidades o personas privadas sea tenida en cuenta para la configuración de la costumbre. En el caso relativo al *Derecho de paso por el territorio de la India*, los que pasaban eran personas físicas, comerciantes con sus mercancías, civiles, además de algunos funcionarios, y fue su conducta la que fue tenida en cuenta directamente para la generación de la costumbre²¹. En casos como este, en realidad puede focalizarse la conducta en dichos individuos o grupos de individuos, que transitaban aunque no lo hicieran de manera expresa en nombre del Estado al que pertenecían. Sin embargo, la relación entre los Estados, para dar lugar al nacimiento de la costumbre, está dada porque un Estado permitió a otro que sus nacionales transitaran por su territorio sin impedirlo.

1.1.2. El transcurso del tiempo

Como dijimos, tradicionalmente se ha requerido para la formación de una costumbre internacional que transcurra un considerable período de tiempo. **No existe un plazo determinado y dependerá de la cuestión de que se trate, pero en general se ha dado en largos períodos.** Sin embargo, parecería que la comunidad internacional actual requiere menos tiempo y repetición que la que se necesitaba en el pasado para la formación de una costumbre²².

La CIJ ha aceptado en el caso de *Plataforma Continental del Mar del Norte* que el tiempo puede no ser extenso:

A pesar de que el paso de solo un breve período de tiempo no es necesariamente, o en sí mismo, un impedimento para la formación de una nueva norma de derecho inter-

17 Mendelson, Maurice H., *op. cit.*, p. 201.

18 Un ejemplo de esto podría ser la modificación por la práctica del sistema de votación en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, a pesar de que la Carta en su letra establece que para la adopción de una resolución de fondo hacen falta nueve votos, "incluso los votos afirmativos de todos los miembros permanentes" (énfasis agregado) -art. 27(3) -; en virtud de la práctica seguida por la Organización, la abstención o la ausencia ya no se consideran veto, por lo que una resolución de fondo se adoptará *sin el voto negativo* de los cinco miembros permanentes.

19 Pellet, Alain, "Article 38", en *The Statute of the International Court of Justice. A Commentary*, Zimmermann, Andreas; Tomuschat, Christian y Oellers-Frahm, Karin (eds.), Oxford University Press, Oxford, 2.º ed., 2012, pp. 749-750, parág. 214.

20 Mendelson, Maurice H., *op. cit.*, p. 208.

21 *Derecho de paso por el territorio de la India* (Portugal c. India), CIJ, Fallo, 08/06/1960.

22 Wolfke afirma que el requerimiento de que la práctica sea ininterrumpida, consistente y continua ya no puede sostenerse; citado por Kammerhofer, Jörg, *op. cit.*, p. 630. Ver también el apartado 7 de este capítulo: "Costumbre tradicional y costumbre moderna".

nacional consuetudinario en base a lo que era originalmente una norma puramente convencional, un requisito indispensable sería que durante el período de tiempo en cuestión, por corto que fuera, la práctica estatal, incluida la de aquellos cuyos intereses están especialmente afectados, haya sido tanto extensiva como virtualmente uniforme [...]²³.

Incluso un autor, frecuentemente citado, -Bin Cheng- afirmó la posibilidad de que existiera una costumbre instantánea²⁴. Con motivo de la adopción de las Resoluciones de la Asamblea General 1721 (XVII) y 1962 (XIII), las primeras relativas al espacio ultraterrestre, se pregunta acerca de la posibilidad de que la adopción unánime de resoluciones, a pesar de que por su naturaleza no sean vinculantes, pueda dar lugar a la formación inmediata de una costumbre internacional. Cheng no ve motivos por los que una costumbre no pueda generarse a partir de este tipo de resoluciones, que serían evidencia de la *opinio iuris* de la comunidad internacional, sin necesidad de práctica por parte de los Estados, ya que para este autor el elemento material no sería constitutivo de la costumbre internacional²⁵. Este jurista no parece contar con muchos seguidores²⁶. El término "costumbre instantánea" es para muchos una contradicción *in terminis*, puesto que siempre transcurre al menos algún tiempo hasta que una práctica deviene en habitual entre los Estados²⁷.

En este orden de ideas, también cabe mencionar la *coutume grande vitesse*, a la que se refiere Condorelli con referencia a la rápida formación de costumbres relativas a crímenes cometidos en conflictos no internacionales tras los conflictos en la antigua Yugoslavia y Ruanda²⁸.

1.1.3. La uniformidad

Con respecto a la uniformidad, en el caso sobre el *Derecho de asilo*, la CIJ consideró que los hechos que se le plantearon presentaban tanta discrepancia en el ejercicio del asilo diplomático que no era posible establecer un uso constante y uniforme²⁹.

Sin embargo, en otros casos, la Corte se ha mostrado satisfecha con determinar que la práctica era "virtualmente uniforme"³⁰, aplicando un estándar más flexible. Así, en el caso de las *Acciones militares y paramilitares en y contra Nicaragua* (en adelante, caso *Nicaragua*), no se consideró que, para que una regla fuera establecida como costumbre, la práctica correspondiente deba estar en absoluta rigurosa conformidad con la regla³¹. Resulta suficiente que la práctica resulte consistente con la regla. No obstante, el alcance de tal concepto resulta algo ambiguo, ya que no es claro qué nivel o medida de "consistencia" será el requerido para que se configure la costumbre. Lo cierto es que la Corte en el citado caso afirma que invocar excepciones o justificaciones para prácticas inconsistentes con la norma no la debilita, sino que la reafirma.

1.1.4. La generalidad

Con relación a la generalidad, no es necesario que todos los miembros de la comunidad internacional realicen la mentada práctica para que pueda dar lugar a la formación de una costumbre internacional; lo que se requiere es que los Estados relevantes para una cuestión determinada participen de la práctica. Barberis lo expresa muy claramente cuando explica que, para demostrar la existencia de una costumbre sobre pesca marítima, se recurrirá a la

23 *Plataforma continental del Mar del Norte*, doc. cit., parág. 74 (traducción libre).

24 Cheng, Bin, "United Nations Resolutions on Outer Space: 'Instant' International Customary Law?", *Studies in International Space Law*, Clarendon Press, Oxford, 1987, pp. 125-149.

25 *Ibid.*, pp. 138 y 139.

26 En contra, ver Pellet, Alain *op. cit.*, p. 750, parág. 215, quien afirma que no existe tal cosa como la costumbre instantánea. Kammerhofer *op. cit.*, p. 630) explica que Cheng considera que no hace falta el elemento material para la formación de la costumbre, en consecuencia, si no se requiere la práctica, no se requiere ni mucha ni poca; por lo tanto, quedaría fuera del espectro de lo que estamos analizando.

27 Mendelson, Maurice H., *op. cit.*, p. 210.

28 Citado por Treves, Tullio, *op. cit.*, parág. 24.

29 *Caso relativo al derecho de asilo* (Colombia c. Perú), CIJ, Fallo, 20/11/1960, párrs. 266-277.

30 Pellet, Alain, *op. cit.*, p. 751, parág. 216.

31 *Acciones Militares y Paramilitares en y contra Nicaragua*, doc. cit., Fallo (fondo), 27/06/1986, parág. 166.

práctica de determinados países (quizás aquellos que tienen grandes flotas pesqueras, o bien los que realizan concesiones de pesca en aguas bajo su jurisdicción), mientras que, para cuestiones relativas a la inmunidad de los cónsules, se consultará la de otros; en este sentido, puede decirse que existen Estados que son "representativos" cuando se trata de una actividad en particular³². Esto es confirmado por la jurisprudencia en los casos de la *Plataforma Continental del Mar del Norte*, en los cuales la CIJ afirma que debe tenerse en cuenta la práctica de los Estados cuyos intereses están especialmente afectados³³.

1.2. La *opinio iuris sive necessitatis*

El elemento psicológico de la costumbre es la creencia que deben tener aquellos que realizan la práctica de observarla con la convicción de estar a derecho, es decir, como si se tratase de una norma jurídica.

El elemento psicológico de la costumbre ha sido objeto de gran debate en la doctrina, incluso hay autores que afirman que no existe o es irrelevante³⁴. Al tratarse de un elemento subjetivo, muchos expresan la dificultad de probar cuál era la intención del Estado al comportarse de determinada manera³⁵. Se observan principalmente dos líneas de pensamiento, 1) los voluntaristas, que encuentran la explicación en el consentimiento de los Estados —como los Estados son soberanos, no pueden ser obligados sin su consentimiento— y, por lo tanto, ven a la costumbre como un tratado tácito³⁶; y 2) otro grupo, que **basa la obligatoriedad de la costumbre en la creencia de la obligatoriedad jurídica de determinada práctica; esta creencia es la denominada *opinio iuris sive necessitatis***³⁷. Dicha controversia se ha dado sobre todo en el plano académico.

La Corte Internacional de Justicia, por su parte, ha afirmado en varios casos que **el elemento subjetivo debe estar presente en el proceso de formación de la costumbre; si falta la**

32 Barberis, Julio A., *op. cit.*, p. 88; Akhurst, Michael, *op. cit.*, p. 28.

33 *Plataforma continental del Mar del Norte*, doc. cit., parág. 73.

34 Mendelson cree que el elemento subjetivo es de poco valor, estima que no es necesario establecer la presencia de *opinio iuris* ni de consentimiento en la mayoría de los casos, ver *op. cit.*, pp. 246, 285 y 290; otros autores afirman que el elemento psicológico no desempeña ningún papel en el proceso de formación de la costumbre: Kopelmanas, Guggenheim y Kelsen, estos últimos dos fueron de esa postura, pero luego modificaron su posición; ver, Barberis, Julio A., *op. cit.*, pp. 92-93.

35 Barberis explica que la dificultad de probar la *opinio iuris* no sería un indicio de su inexistencia; la compara con la dificultad de probar la culpa o el dolo en derecho penal; Barberis, Julio A., *op. cit.*, p. 98.

36 Por ejemplo, la doctrina soviética, Tunkin. Asimismo, Anzilotti es uno de los principales exponentes de esta doctrina. Wolfke, por su parte, es voluntarista pero afirma que la costumbre no es un tratado tácito, por ejemplo, las personas que pueden colaborar en la formación de la costumbre son más que los que tienen la facultad para celebrar tratados, ver Mendelson, Maurice H., *op. cit.*, p. 254.

Esta doctrina no parece adecuada para explicar la realidad internacional, pues presume que aquellos Estados que no se han manifestado respecto de una práctica han prestado su aquiescencia a ella, es decir, han quedado obligados a través de su consentimiento tácito. No parece razonable que Estados que no tienen interés alguno en una práctica, y no se ven por ella afectados, protesten solo para prevenir que en un futuro tal práctica no le sea aplicable. Puede darse también la situación de que un Estado no esté siquiera enterado de la práctica. Estos Estados, por lo tanto, no han hecho nada respecto de la práctica, pero de ello no puede concluirse que, como no han protestado, por su pasividad han prestado su aquiescencia; se trataría de una ficción.

Esta doctrina tampoco explica por qué los nuevos Estados están obligados por las costumbres existentes; si bien podrían oponerse a ellas comenzando prácticas contrarias y desarrollando nuevas costumbre; hasta que ello ocurra la doctrina y la jurisprudencia son pacíficas en afirmar que los nuevos Estados están obligados por el derecho consuetudinario existente.

37 Un problema para los doctrinarios es la llamada "paradoja de la *opinio iuris*". Debe haber una creencia errónea de parte de los creadores de la costumbre de que ya están obligados legalmente por la misma norma que están en proceso de crear (Kammerhofer, Jörg, *op. cit.*, p. 534). Barberis explica que esto no es una contradicción lógica, lo sería si la concepción tradicional exigiera que para crear una norma hubiera una norma preexistente del mismo contenido que la norma de costumbre que se va a crear, pero no se exige que exista, sino que los sujetos se comporten creyendo que exista. Podría haber contradicción entre dos proposiciones, una que postula un objeto como existente y otra que lo niega; o una que postula la creencia en la existencia de un objeto y otra que niega esa creencia. Sin embargo, no hay contradicción lógica entre dos proposiciones, de las cuales una expresa la creencia en la existencia de un objeto y la otra niega su existencia; Barberis, Julio A., *op. cit.*, pp. 93 y 94.

opinio iuris, no hay norma consuetudinaria (aunque debe mencionarse que en algunos casos la Corte no se detiene a investigar si el elemento subjetivo está presente)³⁸.

La *opinio iuris* diferencia a la costumbre de un mero uso o hábito. Existen actos que, por ejemplo, los individuos realizan por una cuestión de higiene o de coquetería, como el lavarse los dientes o el ponerse desodorante; son hábitos que se reiteran en el tiempo de manera constante y uniforme, pero nadie los realiza con la convicción de que no hacerlo podría llevarlo a **enfrentar una demanda en sede judicial** (aunque muchos de nosotros alguna vez hubiéramos deseado poder demandar al pasajero que viajaba a nuestro lado en el subterráneo atestado, pero todos sabemos que el aseo personal no es exigible jurídicamente). Los Estados también realizan algunos actos por motivos que no son jurídicos, como pueden ser de índole político, o por cortesía, por ejemplo, algunos actos relacionados con la recepción y trato a jefes de Estado o de gobierno o el orden de prelación de los representantes de Estados en los actos. **Son prácticas que se repiten, pero los Estados no las realizan con la convicción de que se trata de una obligación jurídica, sino movidos por otras intenciones.**

Sobre esta cuestión se expidió la CIJ en los casos de la *Plataforma Continental del Mar del Norte* cuando afirmó que, si bien existía una cantidad de Estados que habían utilizado el principio de equidistancia para delimitar su plataforma continental, los motivos que los habían llevado a utilizarlo pudieron haber sido la practicidad o el interés, pero no la convicción de estar cumpliendo con una norma jurídica; lo que la llevó a establecer que el principio de equidistancia consagrado en el artículo 6 de la Convención de Ginebra sobre Plataforma Continental (1958) no se trataba de una norma consuetudinaria. Así, la Corte afirmó:

No sólo los actos deben adecuarse a una práctica establecida; además deben ser tales o llevarse a cabo de tal manera, que evidencien la creencia de que tal práctica es obligatoria en virtud de la existencia de una norma que así lo establece. La necesidad de tal creencia, esto es, la existencia del elemento subjetivo, está implícito en la noción de *opinio iuris sive necessitatis*. Los Estados involucrados deben pues sentir que están cumpliendo con una obligación jurídica. La frecuencia, o el carácter habitual de los actos no son en sí mismos suficientes. Existen muchos actos internacionales, por ejemplo en el campo de ceremonial y protocolo, que se realizan casi invariablemente, pero que están motivados sólo por consideraciones de cortesía, conveniencia o tradición y no por un sentido de deber legal³⁹.

En el caso *Nicaragua*, la Corte hace referencia a la necesidad de establecer no solo la práctica, sino también la *opinio iuris* de los Estados. "Para que se forme una nueva norma consuetudinaria los actos deben corresponderse con una práctica establecida, sino que debe también estar acompañados por la *opinio iuris sive necessitatis*"⁴⁰.

En época reciente, en el caso sobre *Inmunidades jurisdiccionales del Estado* (Alemania c. Italia) afirmó:

La Corte debe determinar, de acuerdo con el artículo 38(1)(b) de su Estatuto la existencia de "costumbre internacional como prueba de una práctica generalmente aceptada como derecho" que confiere inmunidad a los Estados y, en su caso, cual es el sentido y alcance de tal inmunidad. Para ello deberá aplicar los criterios que repetidamente ha establecido para la identificación de una norma de derecho internacional consuetudinario. En particular [...] se requiere que exista "una práctica establecida" junto con *opinio iuris*⁴¹.

38 Pellet, Alain, *op. cit.*, p. 751, parág. 217 y nota 562 (cita a Mendelson, en *Fifty Years of the International Court of Justice*, pp. 63 y 70 y los ejemplos allí citados). Además, ver Mendelson, Maurice H., *op. cit.*, pp. 250-251.

39 *Plataforma continental del Mar del Norte*, doc. cit., parág. 77 (traducción libre).

40 *Actividades militares y paramilitares en y contra Nicaragua*, doc. cit., Fallo (fondo), 27/06/1986, parág. 207 (traducción libre).

41 *Inmunidades jurisdiccionales del Estado* (Alemania c. Italia), CIJ, Fallo, 03/02/2012, parág. 55 (traducción libre).

Algunos autores que han visto en resoluciones de la Asamblea General, cuya naturaleza jurídica es *no vinculante*, una expresión de la *opinio iuris* de los Estados, entienden que aquellas resoluciones que son adoptadas por amplias mayorías o por unanimidad, y que se reiteran año tras año, palabras más palabras menos, en el seno de la Organización, darían una pauta de lo que los Estados entienden que sería deseable fuera obligatorio⁴².

La CIJ, por su parte, ha hecho gran uso de las resoluciones de la Asamblea General de las Naciones Unidas para probar la existencia de la *opinio iuris*⁴³. En la Opinión Consultiva sobre *Legalidad de la amenaza o el empleo de armas nucleares* afirma: "Las resoluciones de la Asamblea General, aun cuando no son vinculantes, pueden a veces tener un valor normativo. Pueden, en determinadas circunstancias, aportar evidencia de importancia para establecer la existencia de una norma o del surgimiento de una *opinio iuris*"⁴⁴.

Si bien una conclusión de este tenor podría resultar razonable, hay que tener cuidado en dar esto por sentado, ya que deberá considerarse que los Estados se expresan en las resoluciones de la Asamblea General sabiendo que estas no son jurídicamente vinculantes y que, por lo tanto, no acarrearán para ellos obligación alguna. Si los Estados se limitan a expresarse año tras año en la Asamblea sin tomar ninguna otra medida, no es fácil desprender de ello que pretendan que una práctica sea obligatoria, es decir que hay dos caras en una misma moneda y hay que ser cauto al extraer conclusiones.

Otro modo común para probar la *opinio iuris* es la referencia a convenios de codificación, a los que nos referiremos más adelante en el punto 4. En los casos de la *Plataforma Continental del Mar del Norte* la CIJ analizó si el artículo 6 de la Convención de Ginebra sobre Plataforma Continental (1958) reflejaba o cristalizaba el método de la equidistancia respecto de la delimitación de la plataforma entre Estados con costas enfrentadas o adyacentes como costumbre internacional⁴⁵.

2. Tipos de costumbre

Existen distintos tipos de costumbre: la costumbre general y la costumbre particular o especial. Esta última puede subdividirse en costumbre regional y costumbre bilateral.

2.1. La costumbre general

La costumbre general es aplicable a todos los miembros de la comunidad internacional⁴⁶. Como ya dijimos, no es necesario que todos los Estados hayan participado en su formación. La costumbre general se aplica no solo a aquellos Estados cuya práctica dio lugar a la formación de la costumbre, sino también a aquellos cuya práctica ni apoya ni rechaza la costumbre⁴⁷; es decir, a todos los Estados de la comunidad internacional⁴⁸, incluso aquellos que han nacido a la vida internacional con posterioridad a la existencia de la costumbre y que, por tanto, no han tenido oportunidad de manifestarse ni a favor ni en contra de la norma⁴⁹. A este tipo de costumbre en ocasiones se la denomina también "derecho internacional general" o "derecho de gentes".

42 Por ejemplo: Asamoah, Akehurst, Suy, Thirlway, Arangio Ruiz, citados por MacGibbon, Iain, "Means for the Identification of International Law, General Assembly Resolutions: Custom, Practice and Mistaken Identity", en *International Law: Teaching and Practice*, Cheng, Bin (ed.), Stevens & Sons, Londres, 1982, p. 19.

43 Pellet, Alain, *op. cit.*, p. 783, parág. 222 (cita los casos: *Nicaragua*, parág. 184, *Golfo de Maine*, parág. 94 y 111) además, las Opiniones Consultivas del *Sahara occidental* y *Namibia*.

44 *Legalidad de la amenaza o el uso de armas nucleares*, doc. cit., parág. 70 (traducción libre).

45 Pellet, Alain, *op. cit.* p. 784, parág. 223.

46 *Plataforma continental del Mar del Norte*, doc. cit., parág. 68.

47 Akehurst, Michael, *op. cit.*, p. 28.

48 La mayoría de la doctrina exceptúa a aquellos que se hayan opuesto desde el nacimiento de la costumbre, ver *infra* apartado siguiente.

49 Este es otro indicio de que la costumbre no es un tratado tácito, en el que es necesario el consentimiento de los Estados, ver *supra* apartado 1.2.

2.1.1. El objetor persistente

Una vez que una norma consuetudinaria de carácter general ha sido establecida, los Estados no pueden de manera unilateral eximirse de la obligación impuesta por dicha norma⁵⁰. No obstante ello, un Estado puede evitar quedar sujeto a una costumbre general si prueba haberse opuesto a la práctica desde su inicio; es lo que se denomina la "doctrina del objetor persistente".

Un Estado que se opone antes de que la costumbre se haya desarrollado como norma jurídica de derecho internacional general puede, en virtud de su objeción, excluirse de la aplicación de la norma.

Aunque la mayoría de la doctrina hace referencia a esta defensa, hay autores que afirman que no tiene fundamento jurídico en derecho internacional, y critican que muchos de los que la apoyan no tienen dificultad en reconciliarla con el rechazo a la necesidad de que un Estado consienta a las normas de derecho internacional⁵¹.

Lo cierto es que son escasos los ejemplos en la jurisprudencia internacional⁵². Podemos mencionar el caso de las *Pesqueras anglo-noruegas*, en el que la CIJ debía constatar si existía una costumbre que prohibía el cierre de las bocas de las bahías con líneas rectas que excedieran las diez millas marinas, y afirmó que no había suficiente práctica general y uniforme para determinarlo, pero, además, agregó que, aun cuando la mencionada costumbre existiera, no resultaría aplicable a Noruega, que se había opuesto a dicha práctica desde el comienzo⁵³.

La práctica internacional también parece ser escasa; sin embargo, ello resulta razonable teniendo en cuenta que las protestas no suelen hacerse por cualquier motivo. Además, se trata de actos diplomáticos que no siempre reciben publicidad de parte de quien los realiza ni de quien los recibe. Asimismo, un Estado que no desea que se le aplique una costumbre preferirá basar su argumento en que tal costumbre no existe, en vez de enrolarse en la excepción de que no resultaría de aplicación a su Estado por tratarse de un objetor persistente; como consecuencia, es dable esperar que no existan tantos ejemplos en la práctica⁵⁴.

Los antecedentes que suelen mencionarse son las objeciones realizadas por Japón, el Reino Unido y los Estados Unidos a las pretensiones de ciertos Estados de ampliar la zona de pesca exclusiva de tres millas marinas a doce, y luego a doscientas, entre mediados de los años sesenta y principios de los años ochenta. Finalmente, a pesar de la tenaz oposición, el estatus de objetor persistente fue de poco valor frente a las fuerzas de cambio en la comunidad internacional que impulsó igualmente los nuevos derechos. Para algunos, entonces, no hay pruebas persuasivas en la práctica de que un Estado tenga el derecho de excluirse de la aplicación de una norma consuetudinaria general⁵⁵.

Desde otro punto de vista, el hecho de que Japón, el Reino Unido o los Estados Unidos hayan abandonado su posición para algunos autores⁵⁶ nada dice de la existencia en derecho de la doctrina del objetor persistente, puesto que el cambio en la postura puede deberse a cuestiones políticas, o a que hayan evaluado el costo de mantener su posición; por ejemplo, ellos debían permitir a los demás pescar a tres millas marinas de sus costas, mientras que sus buques pes-

50 Elias, Olufemi, "Persistent Objector" (2009), en *Max Planck Encyclopedia of Public International Law*, <http://www.mpepil.com>, parág. 1.

51 Se oponen a la doctrina: D'Amato, Anthony, *The Concept of Custom*, Cornell University Press, Londres, 1971, pp. 285-288; Charney, Jonathan I., "The Persistent Objector Rule and the Development of Customary International Law", *B.Y.I.L.*, vol. 56 (1985), p. 1.

52 Cfr. Elias, Olufemi, *op. cit.*, parág. 7 y ss.

53 *Pesqueras* (Reino Unido c. Noruega), CIJ, Fallo, 18/12/1951, p. 151. Aunque este es el caso al que siempre se hace mención al referirse a la doctrina del objetor persistente, algunos autores han dicho que en realidad se trataba de un caso de costumbre especial (D'Amato, Anthony, "The Concept of Special Custom in International Law", *A.J.I.L.*, vol. 63, n.º 2 [1989], p. 221). Ver también comentario de Charney, Jonathan I., *op. cit.*, p. 8. También se ha sostenido que la afirmación se trataba solo de un *obiter dictum* (ver Mendelson, *op. cit.*, p. 239). Se ha señalado, además, que la Corte se refirió a la objeción persistente solo en casos en los cuales no era clara la existencia de la costumbre general (ver también caso sobre el *Derecho de asilo*).

54 Mendelson, Maurice H., *op. cit.*, p. 234.

55 Charney, Jonathan I., *op. cit.*, p. 12.

56 Mendelson, Maurice H., *op. cit.*, p. 237.

queros eran excluidos de las aguas adyacentes a otros Estados, es decir que la aceptación de la nueva tendencia por parte de los objetores puede simplemente haberse debido a una cuestión de interés y nada nos dice de su posición legal.

Por último, cabe señalar que esta oposición a la formación de una costumbre se torna ineficaz cuando la norma consuetudinaria a la cual un Estado se opone tiene carácter de *ius cogens*. El ejemplo más frecuente en la literatura es el de la costumbre que prohíbe la política del *apartheid*; no obstante la oposición reiterada de Sudáfrica a la formación de la mencionada costumbre, ese Estado está obligado por la norma⁵⁷.

2.2. La costumbre particular o especial

La costumbre particular, a diferencia de la general, **se aplica solo a un número reducido de Estados**; se trata de aquellos que han participado en su formación o bien que puede probarse que participan de dicha práctica. **Suele distinguirse entre costumbre regional y bilateral.**

La costumbre regional⁵⁸ se refiere a un grupo de Estados que han llevado adelante una práctica particular. Un ejemplo es el caso del instituto del asilo en Latinoamérica, que fue objeto de análisis por parte de la CIJ en el caso relativo al *Derecho de asilo*⁵⁹, en el que un nacional peruano -Haya de la Torre- solicitó asilo diplomático en la embajada de Colombia en Perú. Colombia afirmaba que el Estado que asila podía calificar unilateralmente el delito, es decir, establecer si se trataba de un delito común o político, mientras que Perú afirmaba lo contrario. Colombia basaba sus argumentos en una costumbre internacional regional latinoamericana. La Corte sostuvo:

La parte que se apoya en una costumbre de este tipo debe probar que dicha costumbre ha sido establecida de tal manera que ha devenido en obligatoria para la otra parte. El Gobierno de Colombia debe probar que la regla invocada por éste es conforme con un uso constante y uniforme practicado por los Estados en cuestión, y que éste uso es la expresión de un derecho perteneciente al Estado que concede el asilo y un deber que le corresponde al Estado territorial⁶⁰.

Pero la Corte concluyó que Colombia no pudo probar la participación de Perú en dicha costumbre y, por lo tanto, no podía oponérsela a Perú.

Aun cuando pudiera suponerse que tal costumbre existe sólo entre determinados Estados Latinoamericanos, no podría invocarse contra Perú que, lejos de haber por su actitud adherido a ella, la ha, al contrario, repudiado negándose a ratificar las Convenciones de Montevideo de 1933 y 1939, que fueron las primeras en incluir una regla concerniente a la calificación del delito en materia de asilo diplomático⁶¹.

A su vez, **la costumbre bilateral es aquella en la que participan solo dos Estados**. En el caso del *Derecho de paso por el territorio de la India* la CIJ afirma:

Es difícil ver por qué el número de Estados entre los que debe establecerse una costumbre local con base a una larga práctica debe necesariamente ser más de dos. La

57 Barberis, Julio A., op. cit., p. 111; ver *Consecuencias jurídicas que tiene para los Estados la continuación de la presencia de Sudáfrica en Namibia (África Sudoccidental)*, no obstante lo dispuesto en la Resolución 276 (1970) del Consejo de Seguridad, CIJ, Opinión Consultiva, 21/06/1971, pp. 57 y 58.

58 A pesar de que muchos autores así la denominan, coincidimos con Akehurst y Mendelson en que es erróneo asumir que una costumbre limitada a un grupo de Estados tiene que ser regional, ya que puede ser restringida a un grupo ideológico o a un grupo que comparte políticas en determinada materia, o característica, como ser poseedores de petróleo, independientemente de su localización. Ver Akehurst, Michael, op. cit., p. 28. Un buen ejemplo serían los Estados llamados *marginalistas* respecto de prácticas relativas a la plataforma continental. Entonces, el término regional no abarca todas las situaciones, quizás un término más adecuado sería el de costumbre especial.

59 *Caso relativo al derecho de asilo*, doc. cit.

60 *Ibid.*, parág. 276 (traducción libre).

61 *Ibid.*, parágs. 277-278 (traducción libre).

Corte no ve motivos por los que una práctica de larga data entre dos Estados aceptada por estos como regulando sus relaciones mutuas no deba constituir la base de los mutuos derechos y obligaciones entre ambos Estados⁶².

En ese caso Portugal poseía una serie de territorios en la India y, debido a un levantamiento que se había producido en 1954, pretendió atravesar el territorio de la India con fuerza armada y municiones con el objeto de sofocar la revuelta. La India le impidió el paso por su territorio, motivo por el cual Portugal incoó acciones ante la CIJ basándose en un derecho de paso consuetudinario que posibilitaba la comunicación entre los territorios portugueses de Daman y los enclaves Dadra y Nagar-Aveli. La Corte concluyó que tal derecho existía con relación al paso de civiles y mercaderías, pero no respecto del paso de fuerzas armadas, para lo que siempre se había solicitado permiso⁶³.

3. La prueba de la costumbre

3.1. Carga de la prueba

En principio, se presume que un tribunal conoce el derecho y puede aplicar la costumbre aun cuando no haya sido expresamente alegada. En la práctica, **quien alega una costumbre tiene la carga de la prueba**, cuya naturaleza variará de conformidad con la materia y los alegatos⁶⁴.

Por su parte, **el que alega una costumbre particular deberá probar que la costumbre fue establecida de manera tal que ha devenido en obligatoria para la otra parte**⁶⁵. Por el contrario, **si se alega la existencia de una costumbre general de carácter evidente, frecuentemente no es necesario probarla**; en tal caso será el Estado que sostiene su inexistencia o **que aquella no lo obliga el que deberá probar que existe práctica que la contradice**, o que ha realizado actos de protesta u objetado de manera persistente al momento de la formación de dicha norma⁶⁶.

En algunos casos la CIJ simplemente afirma la existencia de una costumbre internacional, sin detenerse a investigar la práctica de los Estados ni la *opinio iuris*, y quizás en algunos casos esto resulta aceptable. No es sorprendente que la CIJ afirme, sin más, que una norma, como la libertad de la alta mar, es una norma bien establecida en derecho internacional; como dice Mendelson, no hace falta reinventar la rueda⁶⁷.

En el mismo orden de ideas, Barberis explica que hay prácticas que han adquirido un grado tal de vigencia en la comunidad internacional que son evidentes y, por lo tanto, un tribunal se limita generalmente a comprobar su existencia. Normas como el principio general de la responsabilidad internacional del Estado, la protección diplomática, *pacta sunt servanda* o la norma de que nadie puede ser juez en su propia causa han sido consideradas como consuetudinarias sin necesidad de una demostración acerca de su formación o de su existencia⁶⁸.

El problema que puede plantearse es que, en algunos casos, se ha afirmado la existencia de reglas que están lejos de ser evidentes⁶⁹.

62 *Derecho de paso por el territorio de la India*, doc. cit., p. 39 (traducción libre).

63 En este caso se trata de una costumbre y está claro que no se trata de un tratado tácito, ya que la práctica de atravesar el territorio de la India había sido realizada a través de los siglos por civiles y mercaderías, es decir, por personas particulares que carecían de *treaty making power* (capacidad para celebrar tratados).

64 Brownlie, Ian, *Principles of Public International Law*, Oxford University Press, Oxford, 5.ª edic., 1998, p. 11.

65 *Caso relativo al derecho de asilo*, doc. cit., parágs. 277-278.

66 Este argumento, en esencia, se encuentra desarrollado en Moncayo, Guillermo; Vinuesa, Raúl y Gutiérrez Posse, Hortensia, op. cit., p. 87.

67 Pellet, Alain, op. cit., pp. 757 y 758, parág. 230 y ss. (para un detalle de los casos ver notas 603 y 604).

68 Barberis, Julio A., op. cit., p. 79 y ss.

69 Pellet, Alain, op. cit., p. 768, parág. 231.

3.2. Medios de prueba

Para probar la costumbre pueden utilizarse los más diversos medios de prueba. No existen reglas específicas en el derecho internacional.

Con el fin de demostrar el elemento material puede recurrirse a múltiples y variados recursos: correspondencia diplomática, escritos o proclamas con protestas, comunicados de prensa, legislación interna, decisiones ejecutivas, órdenes impartidas a las fuerzas armadas, como "reglas de empeñamiento", votos en las organizaciones internacionales, actas de conferencias internacionales, jurisprudencia de tribunales internos. Se ha afirmado que estas conductas deben tener algún grado de publicidad, ya que las conductas secretas o los asesoramiento legales confidenciales, así como las instrucciones o lineamientos a diplomáticos podrían servir en su caso, si tomaran publicidad, como evidencia del elemento subjetivo, es decir, la actitud del Estado con relación a la norma, pero no como evidencia del elemento material⁷⁰.

La CIJ, para determinar la existencia de una práctica, ha mencionado actos administrativos o actitudes, en particular en materia de protección diplomática, legislación, actos judiciales o —este parece ser el más importante y frecuente aspecto de la práctica— los tratados. Sin embargo, respecto a estos últimos, la Corte Permanente de Justicia Internacional ha afirmado que puede darse el caso de que la celebración de un tratado, lejos de ser parte de un proceso consuetudinario, sea un signo de la necesidad de apartarse de una norma consuetudinaria de la cual el tratado constituye una excepción⁷¹. En efecto, por ejemplo, la existencia de numerosos tratados de extradición provee, al menos *prima facie*, prueba de la ausencia de una obligación de extraditar; o la existencia de tratados sobre aeronavegación y las dificultades que conlleva su negociación demuestran que, sin tales acuerdos, los derechos no existirían⁷².

Hace poco tiempo, en el caso sobre *Inmunidades jurisdiccionales del Estado* afirmó la CIJ:

En el presente contexto, la práctica estatal de particular importancia se encuentra en las sentencias de tribunales nacionales que trataron la cuestión relativa a la inmunidad de los Estados extranjeros, en la legislación de aquellos Estados que se refiere a inmunidad, en las demandas incoadas por los Estados ante tribunales extranjeros y en las declaraciones hechas por Estados, primero en el curso del exhaustivo estudio realizado por la Comisión de Derecho Internacional y luego en el contexto de la adopción de la Convención de las Naciones Unidas. La *opinio iuris*, en este contexto, se refleja en particular en la afirmación, de los Estados que reclaman la inmunidad, que el derecho internacional les confiere un derecho a tal inmunidad de la jurisdicción de otros Estados, en el reconocimiento de Estados que conceden la inmunidad, porque el derecho internacional les impone una obligación de hacerlo. [...] Aunque puede ser cierto que los Estados a veces deciden acordar una inmunidad más extensiva que la requerida por el derecho internacional, [...] el otorgamiento de la inmunidad en ese caso no está acompañado por el requisito de *opinio iuris* y, por lo tanto, no arroja luz acerca de la cuestión que está bajo consideración⁷³.

En algunos casos a la Corte le ha parecido suficiente postular que una práctica sobre la que estriba la norma existió, sin tomarse el trabajo de demostrarla⁷⁴.

⁷⁰ Mendelson, Maurice, *op. cit.*, p. 204.

⁷¹ Pollot, Alain, *op. cit.*, pp. 748-749, parágs. 212-213.

⁷² Mendelson, Maurice, *op. cit.*, p. 206.

⁷³ *Inmunidades jurisdiccionales del Estado*, doc. cit., parág. 55 (traducción libre).

⁷⁴ *Ibid.*, p. 748, parág. 211 y nota 536. Pollot sostiene que esta fue la práctica habitual de la Corte Permanente de Justicia Internacional. En el caso *Nicaragua* la Corte consideró suficiente afirmar que las expresiones de una *opinio iuris* con respecto de la existencia del principio de no intervención en el derecho internacional consuetudinario son numerosas y no es difícil encontrarlas. *Actividades militares y paramilitares en y contra Nicaragua*, doc. cit., Fallo (fondo), 27/06/1986, parág. 202. Es cierto que es difícil apoyarse en la práctica para probar una costumbre que prohíbe una conducta.

4. La codificación y el desarrollo progresivo del derecho internacional

La costumbre internacional consiste en una práctica con *opinio iuris*, es decir, se trata de conductas, actos, y por lo tanto, no se encuentra expresada en lenguaje natural.

La Carta de la Organización de las Naciones Unidas determina en su artículo 13 que la Asamblea General promoverá estudios y hará recomendaciones para "fomentar la cooperación internacional en el campo político e impulsar el desarrollo progresivo del derecho internacional y su codificación". Para ello creó —por Resolución 174 del 21 de noviembre de 1947— un órgano subsidiario, la **Comisión de Derecho Internacional (CDI)**, formada por treinta y cuatro miembros elegidos por la Asamblea General, por cinco años, a título personal, es decir, no representan a los Estados de su nacionalidad. A este órgano se le ha encomendado la tarea de la codificación y el desarrollo progresivo⁷⁵.

La codificación consiste en expresar el contenido de las normas consuetudinarias en proposiciones lingüísticas. Como hemos dicho, el derecho consuetudinario no está expresado en términos de lenguaje, por lo cual requiere que se lo vuelque al lenguaje natural, lo que necesariamente conlleva una modificación y una mayor precisión⁷⁶. Además, comprende la sistematización, es decir, agrupar y ordenar las normas que regulan una misma institución jurídica, por ejemplo, la protección diplomática, la responsabilidad internacional o los actos jurídicos unilaterales⁷⁷.

Cuando se realiza la tarea de codificación se advierten, en general, lagunas, pues existen hipótesis que no se han presentado en la práctica o que han ocurrido muy poco y no han dado lugar a una costumbre. En esos casos se trata de completar el derecho consuetudinario proponiendo la regulación de las hipótesis no previstas y se opta por una solución determinada en las que las prácticas internacionales son ambiguas o contradictorias; a esta labor se la llama **desarrollo progresivo**⁷⁸. El estatuto de la Comisión de Derecho Internacional establece en su artículo 15:

[...] la expresión desarrollo progresivo es utilizada, por comodidad, para designar la elaboración de proyectos de convenciones sobre temas que no hayan sido regulados todavía por el derecho internacional o respecto a los cuales no hayan aplicado, en la práctica, normas suficientemente desarrolladas [...]⁷⁹.

La codificación y el desarrollo progresivo han producido efectos en la formación del derecho consuetudinario bajo las modalidades que Jiménez de Aréchaga ha descrito como **los efectos: declarativo, cristizador y generador o constitutivo**⁸⁰.

El primero, el **efecto declarativo**, consiste en que la norma del tratado sea solo la declaración, la expresión formal y por escrito de una norma de derecho consuetudinario ya existente. En este supuesto, la disposición del tratado es pura y simplemente la codificación o enunciación de una norma consuetudinaria en vigor⁸¹.

La CIJ ha referido en numerosas ocasiones a convenciones codificadoras como prueba de la costumbre internacional, afirmando que estas reflejan el derecho consuetudinario. En par-

⁷⁵ Es dable señalar que la codificación puede ser realizada también por los mismos Estados o por otro órgano o institución. Por ejemplo, grandes codificaciones se realizaron respecto de los usos y costumbres de la guerra durante las Conferencias de la Haya de 1864 y 1907. Asimismo, bajo los auspicios del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), los cuatro Convenios de Ginebra de 1949.

⁷⁶ Barberis, Julio A., *op. cit.*, pp. 116 y 118. Ver también Barberis, Julio, "The Customary rule: From Chrysalis to Butterfly", en *Liber Amicorum 'In Memoriam' of Judge José María Ruda*, Armas Baroa, Calixto A. et al (eds.), Kluwer Law International, Amsterdam, 2000, p. 13 (cita autores de la misma opinión, como Jennings y Villiger).

⁷⁷ Barberis, Julio A., *op. cit.*, pp. 116 y 117.

⁷⁸ *Ibid.*

⁷⁹ Estatuto de la Comisión de Derecho Internacional, Resolución 174 (II) de la Asamblea General, 21/11/1947.

⁸⁰ Jiménez de Aréchaga, Eduardo, "International Law in the Past Third of a Century", *R.C.A.D.I.*, vol. 159 (1978-II), p. 14.

⁸¹ Jiménez de Aréchaga, Eduardo et al, *Derecho Internacional Público, principios, normas y estructuras*, t. I, Fundación de Cultura Universitaria, Montevideo, 2005, p. 202.

ricular, ha considerado a la Convención de Viena sobre Derecho de los Tratados (1969) como codificación de normas consuetudinarias existentes. Un ejemplo es la Opinión Consultiva relativa a *Namibia* en la que, aun cuando la mencionada Convención de Viena no había entrado en vigor, la Corte afirmó que el artículo 80 había sido adoptado sin votos en contra y que podía en gran medida considerarse como una codificación del derecho consuetudinario existente sobre la materia⁸².

En época reciente, en este sentido, en el caso de las *Plantas de celulosa en el Río Uruguay* (Argentina c. Uruguay), se refiere al artículo 31 de la Convención de Viena como codificador de las normas de interpretación del derecho internacional general⁸³. Otro ejemplo muchas veces referido por la Corte en este contexto es la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar. En efecto, en el reciente caso *Controversia territorial y marítima* (Nicaragua c. Colombia) ha dicho:

[...] la Corte ha reconocido que los principios de delimitación marítima consagrados en los artículos 74 y 83 reflejan derecho internacional consuetudinario⁸⁴. [...] y considera que el régimen legal de las islas establecido en el artículo 121 de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar forma un régimen indivisible, todo el cual (como Colombia y Nicaragua reconocen) tiene status de derecho internacional consuetudinario⁸⁵.

En ese mismo orden de ideas también afirmó que "la definición de plataforma continental expuesta en el artículo 76, párrafo 1 de la Convención [antes mencionada] forma parte del derecho consuetudinario internacional"⁸⁶.

La CIJ ha mencionado, además, el trabajo de la CDI como medio para establecer la existencia de la costumbre, o de alguno de sus elementos. Incluso se ha referido a sus proyectos, aun antes de que se hayan convertido en convenciones. El caso más llamativo fue el relativo al *Proyecto Gabčíkovo-Nagymaros*, en el que la CIJ citó al menos siete veces el proyecto de artículos sobre responsabilidad internacional del Estado por hecho internacionalmente ilícito adoptado en primera lectura⁸⁷.

Hace poco tiempo, en el caso entre Alemania e Italia sobre *Inmunidades jurisdiccionales del Estado*, la CIJ se refirió al trabajo de la CDI, afirmando que en 1980 dicho órgano concluyó que la inmunidad del Estado había sido "adoptada como una norma general de derecho consuetudinario internacional sólidamente arraigada en la práctica internacional actual de los Estados" y que tal conclusión era fruto de una exhaustiva investigación de la práctica estatal; en opinión de la Corte estaba confirmada por el registro de legislación nacional, decisiones judiciales y los comentarios de los Estados sobre lo que luego se convirtió en la Convención de las Naciones Unidas sobre Inmunidades del Estado y de sus Bienes (2004)⁸⁸.

No obstante, es importante recordar que **el trabajo realizado por la CDI, en el que —como ya se remarcó— sus miembros participan a título personal, no puede equipararse con la práctica de los Estados ni evidencia de *opinio iuris*, aunque, sin duda, es un medio subsidiario para la determinación de reglas de derecho**⁸⁹.

82 *Consecuencias jurídicas que tiene para los Estados la continuación de la presencia de Sudáfrica en Namibia* (África Sudoccidental), no obstante lo dispuesto en la Resolución 276 (1970) del Consejo de Seguridad, doc. cit.

83 *Plantas de celulosa en el Río Uruguay* (Argentina c. Uruguay), CIJ, Fallo, 20/04/2010, parágs. 64-66; Pellet, Alain, op. cit., nota al pie 588.

84 Esto ya lo había afirmado en el caso *Delimitación marítima y cuestiones territoriales entre Qatar y Bahrein* (Qatar c. Bahrein), CIJ, Fallo, 18/03/2001, parágs. 167 y ss.

85 *Controversia territorial y marítima* (Nicaragua c. Colombia), CIJ, Fallo, 19/11/2012, parág. 189 (traducción libre).

86 *Ibid.*, parág. 118.

87 *Proyecto Gabčíkovo-Nagymaros* (Hungría/Eslovaquia), CIJ, Fallo, 25/09/1997, parágs. 47-58 (citado por Pellet, Alain, op. cit., p. 756, parág. 225).

88 *Inmunidades jurisdiccionales del Estado* (Alemania c. Italia), CIJ, Fallo, 03/02/2012, parág. 56.

89 Pellet, Alain, op. cit., p. 756, parág. 226.

El **segundo efecto de la codificación sería el *cristalizador***, referido a que la disposición del tratado constituya la primera formulación en un texto de una costumbre que no había alcanzado su madurez plena, pero que se hallaba en vías de formación, o *in statu nascendi*. **Como consecuencia de su incorporación a un tratado adoptado en una conferencia, queda cristalizada como una norma jurídica de carácter consuetudinario**⁹⁰.

Esta idea de cristalización parece más difícil de aprehender, ya que el punto en el cual comienza a existir una costumbre general puede no ser del todo claro⁹¹. Sin embargo, la Corte afirmó en el caso de la *Jurisdicción en materia de pesquerías*:

Luego de la Conferencia [Segunda Conferencia de Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar] el derecho evolucionó a través de la práctica de los Estados con base en los debates y casi acuerdos de la Conferencia. Dos conceptos se han cristalizado como derecho consuetudinario en años recientes surgidos del consenso general revelado en dicha conferencia. El primero, es el concepto de la zona de pesca, como área en la que el Estado puede reclamar jurisdicción de pesca exclusiva, independientemente de su mar territorial; la extensión de la zona de pesca hasta 12 millas marinas contadas desde las líneas de base parece hoy ser generalmente aceptada. El segundo es el concepto de los derechos preferenciales de pesca en aguas adyacentes a favor del Estado ribereño [...]⁹².

Finalmente, **el efecto generador se refiere a la posibilidad de que la disposición de un tratado, en el momento de su adopción, sea claramente una propuesta de *lege ferenda* y no una norma ya existente o incluso *in statu nascendi***, que suponga no la codificación del derecho existente, sino un desarrollo progresivo potencial de ese derecho. Sin embargo, dicha disposición de un tratado puede constituir el punto de partida de una práctica posterior uniforme de los Estados conforme con dicha disposición, en tal medida que la disposición en cuestión, siguiendo los cauces adecuados, se transforme en una regla de derecho consuetudinario⁹³.

En los casos de la *Plataforma continental del Mar del Norte*, la Corte tuvo que examinar si el artículo 6 de la Convención de Ginebra sobre la Plataforma Continental (1958) —que establecía el principio de la equidistancia en la delimitación de la plataforma continental— había adquirido efecto constitutivo, en los términos que estamos analizando, es decir que, si por su influencia, había originado una nueva norma que, en la fecha de la sentencia (1969), se había incorporado al "corpus" general del derecho internacional consuetudinario. Si bien la Corte entendió que este no era el caso, afirmó con carácter general:

En la medida en que esta tesis se basa en la idea de que el artículo 6 de la Convención ha tenido la influencia y ha producido el efecto descrito, implica claramente que se considera dicho artículo como una disposición creadora de normas que ha servido de base o de punto de partida de una regla que, siendo puramente convencional o contractual en su origen, posteriormente se habría integrado en el "corpus" general del derecho internacional y sería en la actualidad aceptada como tal por la "*opinio iuris*", de manera que habría llegado a ser obligatoria incluso para los países que no son, ni nunca han sido, partes de la Convención. Ciertamente este proceso entra dentro del ámbito de lo posible y ocurre de tiempo en tiempo; constituye, sin duda, uno de los métodos reconocidos en virtud de los cuales pueden formarse nuevas normas del

90 Jiménez de Aréchaga, Eduardo et al., op. cit., pp. 202-203.

91 Para Mendelson la metáfora resulta sospechosa, pues el proceso de cristalización de un líquido o un gas, a pesar de que puede continuar por un tiempo, tiene un momento distintivo y observable en el cual el cristal se forma, lo que no es para nada claro en la costumbre. Lo compara con que no es fácil determinar el punto exacto en que una fruta está madura. Ver Mendelson, op. cit., p. 305.

92 *Jurisdicción en materia de pesquerías* (Reino Unido c. Islandia), CIJ, Fallo, 25/07/1974, ICJ Reports 1974, pp. 20-21, parág. 44 (traducción libre).

93 Jiménez de Aréchaga, Eduardo et al., op. cit., pp. 202-203.

derecho internacional consuetudinario. Pero también no hay que considerar que dicho resultado se alcance con facilidad⁹⁴.

En las dos sentencias de los asuntos sobre *Jurisdicción en materia de pesquerías*, la Corte afirmó la existencia de normas consuetudinarias originadas a través del efecto generador⁹⁵. De hecho, la CIJ reconoció y aplicó normas consuetudinarias que se habían formado en la práctica de los Estados centrada en el núcleo de una propuesta sometida de *lege ferenda* en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar de 1980 y que no llegó a adoptarse por falta de un voto⁹⁶.

5. La relación entre la costumbre y los tratados

Las normas convencionales y consuetudinarias poseen la misma jerarquía en el derecho internacional, esto ha sido tratado en el capítulo 4. En consecuencia, en caso de conflicto de aplicación en un caso concreto entre una costumbre y un tratado, este deberá resolverse utilizando los principios *lex posterior derogat priori* y *lex specialis derogat generali*, a menos que una norma consuetudinaria anterior o general tenga carácter de norma de *ius cogens*, en cuyo caso, por su carácter de imperativa, no puede ser modificada por un tratado, sino únicamente por una norma del mismo carácter⁹⁷.

En el derecho internacional se da la particularidad de que muchas veces coexisten normas de distintas fuentes con el mismo contenido. Ello se debe a la interacción que se produce entre tratado y costumbre y que hemos analizado en el apartado anterior al examinar los efectos de la codificación. Así, un Estado que no fuera miembro de las Naciones Unidas estaría igualmente obligado en sus relaciones internacionales de abstenerse de la amenaza o el uso de la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de cualquier Estado, o en cualquier otra forma incompatible con los propósitos de las Naciones Unidas, ya que esta norma de origen convencional –artículo 2(4) de la Carta de las Naciones Unidas– ha dado lugar a una costumbre internacional de contenido idéntico⁹⁸. Al mismo tiempo, la Carta de las Naciones Unidas codifica normas consuetudinarias como el derecho inmanente a la legítima defensa, regulado en el artículo 51.

La CIJ ha tenido oportunidad de expresarse respecto de esta cuestión en el caso *Nicaragua*, en la fase sobre jurisdicción:

La Corte no puede desestimar los reclamos de Nicaragua basados en principios de derecho consuetudinario y derecho internacional general simplemente porque tales principios han sido recogidos en los textos de las Convenciones sobre las que se apoya Nicaragua. El hecho de que los mencionados principios, reconocidos como tales, han sido codificados o incorporados en convenciones multilaterales no significa que dejen de existir ni de aplicar como principios de derecho consuetudinario, aun respecto de los países que son partes de dichas convenciones⁹⁹.

94 *Plataforma continental del Mar del Norte*, doc. cit., parág. 71 (traducción en Jiménez de Aréchaga, Eduardo, et al., op. cit. p. 207).

95 *Jurisdicción en materia de pesquerías*, doc. cit., p. 21 y ss., parág. 44 y ss.

96 Jiménez de Aréchaga, Eduardo et al., op. cit., p. 207.

97 Ver artículo 63 de la Convención de Viena sobre Derecho de los Tratados (1989). También Barberis, Julio A., op. cit., p. 112; Trevos, Tullio, op. cit., p. 17, parág. 89.

98 Gutiérrez Posse, Hortensia D.T. *Guía para el conocimiento de los elementos de derecho internacional público*, La Ley, Buenos Aires, 2003, p. 28.

99 *Actividades militares y paramilitares en y contra Nicaragua* (Nicaragua c. E.E.U.U.), Fallo (jurisdicción), 24/11/1984, parág. 73 (traducción libro).

6. El denominado *soft law*

El término *soft law*¹⁰⁰ se le atribuye a Lord Mc. Nair, quien lo utilizó para describir “instrumentos con efecto vinculante extra legal”¹⁰¹. En general, **se describe con este concepto a principios, reglas o estándares que no provienen de las fuentes formales del derecho internacional**.

No resulta fácil definir el concepto de *soft law*, ya que **su contenido y alcance son poco precisos**¹⁰². Se trata de un término conveniente para referirse a una variedad de instrumentos que no son jurídicamente obligatorios y que utilizan los Estados y las organizaciones internacionales en sus relaciones internacionales¹⁰³.

Dichos instrumentos elaborados por sujetos de derecho internacional –a diferencia de ciertos códigos de conducta creados por entidades privadas– cuando surgen en el marco de organizaciones internacionales se caracterizan, en general, por expresar las expectativas comunes con relación a determinadas conductas en las relaciones internacionales. Al no provenir de ninguna de las fuentes formales de derecho internacional, no son vinculantes; sin embargo, parecerían producir, al menos de acuerdo con algunos autores, ciertas consecuencias en el orden jurídico internacional¹⁰⁴.

Parte de la doctrina se pregunta si puede tratarse de una nueva fuente de derecho internacional, pero, sin lugar a dudas, la respuesta es negativa. En efecto, esta concepción distingue entre las normas jurídicas que ya poseen plena validez y las que están en vías de consolidarse o instrumentos que tienen carácter de recomendaciones no vinculantes. En realidad, esta distinción es bien conocida; en la doctrina se habla de *lex lata* y de *lex ferenda*. Así, Barberis no encuentra sentido en llamar con un nuevo nombre –*soft law*– a algo que ya tenía su denominación propia¹⁰⁵. No existe en derecho una categoría intermedia, algo *es derecho o no lo es*. Es decir que el *soft law* no crea derecho. Pero, entonces, cabe preguntarse cuál es la relevancia de este concepto tan utilizado en el orden jurídico internacional actual.

En primer lugar, estos instrumentos cobran relevancia en el campo de la buena fe. El principio de la buena fe no los convierte en obligatorios, sin embargo, sobre la base de este los sujetos de derecho no pueden contradecir sus propias conductas; en consecuencia, parece razonable afirmar que un Estado no podría invocar que una conducta es ilegal si él mismo la ha aprobado en un instrumento de *soft law*¹⁰⁶.

Por otra parte, pueden servir, además, como fuente material del derecho internacional, ya que textos de *soft law* pueden constituir una base para negociaciones de un tratado internacional, pues algunas veces resulta más sencillo partir de un texto ya elaborado que comenzar de cero.

100 Algunos autores e instituciones se refieren a él como “derecho blando” (flexible) por oposición al “derecho duro” (*hard law*), tanto en el ámbito del derecho internacional como en los ordenamientos internos. Por ejemplo, ver Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, *Preguntas frecuentes sobre cuestiones de derecho internacional de la lucha contra el terrorismo*, Naciones Unidas, Nueva York, 2009, p. 13 (disponible en <http://www.unodc.org/documents/terrorism/Publications/FAQ/Spanish.pdf>). Ver también Sánchez Pérez, Alexander, *Las normas de derecho blando*, Universidad Externado de Colombia, Bogotá, 2012.

101 Thürer, Daniel, “Soft Law” (2010), en *Max Planck Encyclopedia of Public International Law*, <http://www.mpep-ill.com>, párr. 5.

102 Ver, sobre este tema, D’Aspremont, Jean y Tanja, Aalberts, “Symposium on Soft Law. Which Future for the Scholarly Concept of Soft International Law? Editor’s Introductory Remarks”, *Leiden Journal of International Law*, vol. 26 (2012), pp. 309-312; Ellis, Jays, “Shades of Grey: Soft law and the Validity of Public International Law”, *Leiden Journal of International Law*, vol. 26 (2013), pp. 313-334.

103 Boyle, Alan, “Soft Law in International Law making”, *International Law*, Evans, Malcolm (ed.), Oxford University Press, Oxford, 3.ª edic., 2010, p. 124.

104 Ibid.

105 Barberis, Julio A., op. cit. p. 285. Este autor distingue entre tres acepciones de *soft law*: a) las normas que se encuentran en proceso de formación; b) las normas jurídicas de contenido vago o difuso; c) las resoluciones de la Asamblea General u otras de la misma naturaleza. La afirmación citada se refiere a la primera acepción. Con respecto a la segunda, estamos en presencia de obligaciones jurídicas, la obligatoriedad es la misma, aunque fuera difícil la comprobación de su cumplimiento. Con relación a la última acepción, se trata de instrumentos no obligatorios y no puede hablarse de un orden jurídico intermedio.

106 Thürer, Daniel, op. cit. p. 6.

En efecto, en 1985, la FAO adoptó un código de conducta relativo a la distribución y el uso de pesticidas y, en 1987, el PNUMA elaboró unas directrices sobre intercambio de información para químicos. Dada la creciente preocupación por la exportación de sustancias restringidas a países en desarrollo, ambos instrumentos fueron modificados en 1989 con el objeto de agregar el requisito de consentimiento previo informado para transferencia de sustancias peligrosas y un procedimiento para prestar dicho consentimiento. En 1992, en la Conferencia de Río, se intentó –sin éxito– recoger el procedimiento en un acuerdo obligatorio. Años más tarde, los miembros de ambas organizaciones se embarcaron en negociaciones y en 1998 se aprobó una convención que recogió casi con exactitud el procedimiento FAO/PNUMA¹⁰⁷.

Otro ejemplo se puede ver con referencia a las armas nucleares. A pesar de las obligaciones establecidas en los tratados de no proliferación nuclear, muchas cuestiones sensibles son reguladas predominantemente por recomendaciones de la Agencia Internacional de Energía Atómica. Tales recomendaciones tratan cuestiones técnicas como inventario, control o transporte, con un detalle difícil de acordar en los tratados. También se ocupan de temas de política interna, como agencias de control, a veces sensibles para negociar de manera convencional. Cuando se adquiere un alto nivel de consenso acerca de las mencionadas recomendaciones, los Estados las incorporan en tratados obligatorios, como se hizo con las reglas sobre desechos radioactivos¹⁰⁸.

Otro papel importante que juegan en relación con los tratados es que estos últimos pueden referir o remitir a instrumentos de *soft law* y establecer que las partes deban conformarse a los estándares contenidos en ellos, obligando al Estado a tener en cuenta, para el marco del tratado, el contenido de algunos instrumentos que por su naturaleza no son obligatorios. Hay muchos ejemplos en la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar¹⁰⁹. Así, por ejemplo, el artículo 22 establece que el Estado ribereño podrá exigir a los buques extranjeros que, en el ejercicio del paso inocente, utilicen vías marítimas determinadas; al designar las vías marítimas el Estado ribereño “tendrá en cuenta: a) Las recomendaciones de la organización internacional competente [...]”. Cabe mencionar también los artículos 211(5) y 212 de dicha Convención, que establecen respectivamente que “Para prevenir, reducir y controlar la contaminación causada por buques [...] los Estados ribereños podrán dictar leyes y reglamentos que sean conformes y den efecto a las reglas y estándares internacionales generalmente aceptados y establecidos por conducto de la organización internacional competente [...]” y “Para prevenir, reducir y controlar la contaminación del medio marino desde la atmósfera o a través de ella los Estados dictarán leyes y reglamentos [...] teniendo en cuenta las reglas y estándares, así como las prácticas y procedimientos recomendados [...]”¹¹⁰.

Asimismo, el *soft law* puede resultar útil para la interpretación del derecho internacional.

Respecto del capítulo que nos ocupa, reviste suma importancia la relación entre los instrumentos de *soft law* y la costumbre, ya que aquellos pueden servir de base para la formación de las normas consuetudinarias, facilitando la evolución del derecho internacional¹¹¹.

Por un lado, pueden constituir evidencia de la *opinio iuris* de los Estados en la formación de la costumbre internacional, como, por ejemplo, las resoluciones de la Asamblea General de las Naciones Unidas, como ya se trató.

Por otra parte, pueden actuar como punto de partida para la realización de conductas por parte de los Estados. Así, los Estados de determinada organización o agrupación se comportan de acuerdo con los estándares adoptados de manera constante y uniforme, y lo hacen con la

107 Abbot, Kenneth W. y Snidal, Duncan, “Hard and Soft Law in International Governance”, en *International Organization*, vol. 54, n.º 3 (2000), p. 443. El Convenio de Rotterdam entró en vigor el 24/02/2004.

108 Ibid., p. 436. La Convención conjunta sobre seguridad en la gestión del combustible gastado y sobre seguridad en la gestión de desechos radiactivos entró en vigor el 18/08/2001.

109 Sobre esta cuestión, ver el informe final del “Comité sobre Jurisdicción del Estado ribereño respecto de la contaminación marina”, de la Asociación de Derecho Internacional (ILA), Londres, 2000, pp. 31-36 (disponible en <http://www.ila-hq.org/en/committees/index.cfm/cid/12>).

110 Muchos de estos estándares están contenidos en convenciones internacionales de la OMI, como SOLAS, MARPOL, pero evolucionan constantemente y muchas veces se redactan “directrices” o “planes” en instrumentos de *soft law*.

111 Boyle, Alan, *op. cit.*, p. 138.

convicción de estar a derecho. De ese modo, los mencionados estándares, que no tenían carácter de norma jurídica, transcurrido cierto tiempo habrán devenido en costumbre internacional¹¹².

Entonces, determinadas conductas que no logran el consenso o las voluntades suficientes para convertirse en tratados, o bien que los Estados de manera consciente no están dispuestos a obligarse por estos, al ser recogidos en estos instrumentos no obligatorios, podrán posteriormente quizás, por el camino de la costumbre, imponerse a toda la comunidad internacional.

En última instancia, el impacto práctico de estos instrumentos dependerá de la aceptación por parte de los Estados a nivel nacional y su real aplicación, más allá del estatus legal con que hayan sido adoptados en los foros internacionales. Así, existen numerosos ejemplos¹¹³ en que instrumentos no obligatorios son aplicados en la práctica por los Estados, lo que demuestra que estos bien pueden tener algún impacto normativo¹¹⁴.

Esta aplicación unilateral tras aparejado el inconveniente de que se aplican estándares que no tienen aún naturaleza jurídica y, por lo tanto, no son obligatorios en el orden jurídico internacional; no obstante ello, los demás Estados, para poder participar de algunas actividades en la comunidad internacional, deben adecuarse a las mencionadas exigencias o quedar fuera de la actividad.

7. Costumbre tradicional y costumbre moderna

En tiempo contemporáneo, la costumbre ha sido restituida a su anterior rol protagónico como fuente de derecho internacional. El exitoso trabajo realizado por la CDI y otros cuerpos codificadores habían provocado la ilusión de que el derecho escrito iba a ocupar todo el escenario del derecho internacional¹¹⁵. Sin embargo, tras el auge de la codificación, ha habido un resurgimiento de la costumbre.

En la doctrina parece haber dos tendencias, que se han denominado *costumbre tradicional* y *costumbre moderna*¹¹⁶. Estas suelen verse como alternativas, dado que la primera pone énfasis en la práctica, mientras que la segunda lo hace en la *opinio iuris*.

La *costumbre tradicional* se identifica a través de un proceso inductivo en el que la costumbre general se deriva sobre todo de la práctica y aquiescencia de los Estados. A contrario sensu, la *costumbre moderna* deriva de un proceso deductivo que comienza con declaraciones generales en vez de prácticas particulares de Estados¹¹⁷. La *nouvelle coutume* o *coutume nouvelle vague*, como la denomina Abi Saab, es el resultado de la introducción de textos escri-

112 D'Aspremont, Jean, *Formalism and Sources of International Law*, Oxford University Press, Oxford, 2011, p. 129.

113 Algunos ejemplos pueden ser la implementación del Código de Conducta de la FAO para pesca responsable y del Plan de acción internacional para prevenir, desalentar y eliminar la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada. PAI-INDNR (IPOA-IUU, sus siglas en inglés), que es un documento de carácter voluntario. Argentina, Canadá, Nueva Zelanda, Chile y Japón, entre otros, implementaron planes de acción nacionales para prevenir, desalentar y eliminar la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (ver <http://www.fao.org>). Por otra parte, recientemente se han creado órganos supervisores para controlar el cumplimiento de instrumentos no obligatorios, como, por ejemplo, la Comisión sobre Desarrollo Sostenible que revisa la implementación de la Agenda 21 adoptada en la Conferencia de Río. A veces se requiere que los Estados realicen informes en cumplimiento con declaraciones o programas. Ver Shelton, Dinah, “International law and ‘relative normativity’”, en *International Law*, Evans, Malcolm (ed.), *op. cit.*, p. 165. La Unión Europea, por ejemplo, ha decidido incluir las emisiones de la aviación en su plan de intercambio de emisiones para aviones que despeguen o aterricen en aeropuertos de la Unión Europea, en un esfuerzo por contrarrestar el cambio climático. La decisión unilateral afectaría a la aviación en general imponiendo estándares y consecuentes responsabilidades sobre emisiones que no son obligatorios en el orden jurídico internacional. Ver Scott, Joanna y Rajamani, Lavanya, “EU Climate Change Unilateralism”, *The European Journal of International Law*, vol. 23, n.º 12 (2012), pp. 489-494.

114 Jensen, Øystein, *The IMO Guidelines for Ships Operating in Arctic Ice-Covered Waters. From Voluntary to Mandatory Tool for Navigation Safety and Environmental Protection?*, The Fridtjof Nansen Institut, 2007, p. 23.

115 Barboza, Julio, *op. cit.*, p. 1.

116 Roberts, Anthea Elizabeth, “Traditional and Modern Approaches to Customary International Law: A Reconciliation”, *A.J.I.L.*, vol. 95, n.º 4 (2001), p. 768.

117 Ibid.

tos en el período formativo de la costumbre¹¹⁸. Así, la costumbre moderna se desarrolla rápidamente, pues, en general, lo hace a partir de un texto; puede tratarse de un tratado, resoluciones como las de la Asamblea General o códigos de conducta, como los que mencionamos en el apartado anterior. La inyección de textos abrevia en gran medida el período de formación de una costumbre¹¹⁹. Como ejemplo vemos el caso *Nicaragua*, en el que la CIJ no se detuvo a hacer un serio análisis de la práctica.

Muchos autores concluyen que la **costumbre moderna sería una nueva especie de derecho universal declarativo**, pues se apoya en declaraciones acerca de la práctica, más que en conductas observables. Kirgis intenta trascender este debate y analiza los requisitos de práctica y *opinio iuris* en una escala esquematizada en un eje de coordenadas¹²⁰. Así, ilustra cómo en los casos en que los Estados son muy activos serán necesarias únicamente indicaciones de *opinio iuris* modestas o casi nulas, mientras que, cuando la evidencia de *opinio iuris* es abundante, la necesidad de un comportamiento que le corresponda disminuye o desaparece. Parecería, por ejemplo, que, con relación a determinadas reglas para la protección de derechos humanos —como la prohibición de la tortura—, la opinión a favor de la norma y la ausencia de manifestaciones en contrario se superpone al hecho de que las violaciones son frecuentes. Entonces, en un extremo, para los casos en que existe práctica muy consistente no se requeriría *opinio iuris*; a medida que la práctica es menos frecuente y declina la consistencia, se requeriría mayor *opinio iuris*.

En general, **la falta de énfasis en la práctica en la costumbre moderna se explica porque se la utiliza para crear normas vinculantes relativas a estándares ideales de conducta, o cuestiones morales de importancia**¹²¹. Para continuar con el mismo ejemplo, la prohibición de la tortura expresa más bien el aborrecimiento de la tortura que una descripción precisa de la realidad.

Una cita de Sir Robert Jennings advierte sobre la situación: "La mayoría de lo que hoy perversamente denominamos derecho internacional consuetudinario no sólo no es derecho consuetudinario, ni siquiera se asemeja vagamente al derecho consuetudinario"¹²². Estas tendencias nos llevan a reflexionar sobre la facilidad con que se puede afirmar la existencia de costumbre, haciendo aparecer lo que en realidad es *lege ferenda* como *lex lata*. Lo mismo puede ocurrir cuando se afirma con ligereza que los proyectos de la CDI son costumbre, cuando en muchos casos encierran algún nivel de desarrollo progresivo.

A pesar del renovado interés en el análisis e identificación de las fuentes de las últimas décadas, **la dificultad en identificar la existencia de la costumbre internacional dista de ser una cuestión de nuestros tiempos. No en vano al comienzo de este capítulo nos referimos al proceso de formación de la norma consuetudinaria como misterioso**. Siempre ha sido difícil verificar el momento a partir del cual una costumbre comienza a existir en este sistema descentralizado. La nueva realidad que se presenta en el derecho internacional actual, en el cual contamos con impensadas facilidades en las comunicaciones, proliferación de textos y publicaciones, al contrario de lo que podría haberse esperado, no parece haber facilitado la tarea.

118 Barboza, Julio, *op. cit.*, p. 2.

119 *Ibid.*, p. 3.

120 Kirgis, Frederic L. Jr., "Custom on a sliding scale", *A.J.I.L.*, vol. 81, n.º 1 (1987), pp. 149-150.

121 Roberts, Athesa Elizabeth, *op. cit.*, p. 766.

122 Jennings, Robert Y., "Identification of International Law", en *International Law: Teachings and Practice*, *op. cit.*, pp. 8-9 (traducción libre). Jennings sostenía que el derecho internacional atravesaba un período de cambios rápidos y desarrollo de gran importancia. La costumbre se caracteriza por el paso del tiempo; se desarrolla lentamente y es difícil de cambiar. Los requisitos de práctica y *opinio iuris* no están presentes en muchas de las normas recientes; da como ejemplo que la práctica de poco servirá para determinar si es lícita la minería unilateral en los fondos marinos y oceánicos. A fines del siglo XX, la mayoría de las normas que no son provenientes de un tratado no reúnen las características de la costumbre; en consecuencia, para este autor es hora de reconocer que no se trata de costumbre.

CAPÍTULO 6

DERECHO DE LOS TRATADOS (PRIMERA PARTE)

CONCEPTO, CLASIFICACIÓN, CELEBRACIÓN, ENTRADA EN VIGOR, OBSERVANCIA, APLICACIÓN, MODIFICACIÓN Y ENMIENDA DE LOS TRATADOS

Silvina S. González Napolitano

1. Introducción: el derecho de los tratados y su codificación

Podemos definir al "derecho de los tratados" como el conjunto de normas internacionales —consuetudinarias y convencionales— que regulan la celebración, aplicación, interpretación, validez y vigencia de los tratados internacionales.

La Comisión de Derecho Internacional (CDI) de las Naciones Unidas se ha ocupado de codificar las normas consuetudinarias relativas al derecho de los tratados internacionales. Luego de varios años de trabajo¹, dicho órgano elaboró un primer anteproyecto que sirvió de base para la negociación y adopción de un tratado sobre la materia en la Conferencia de Viena de 1968-1969²: la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados de 1969 (en adelante, la Convención de Viena de 1969)³.

Con posterioridad, y también sobre la base de otro anteproyecto elaborado por la CDI⁴, la Asamblea General convocó a una conferencia en 1986, donde se adoptó la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados entre Estados y Organizaciones Internacionales o entre Organizaciones Internacionales de 1986 (en adelante, la Convención de Viena de 1986)⁵.

1 Apenas comenzó a funcionar la CDI en 1948, uno de los temas que figuraba en su agenda era la codificación del derecho de los tratados, al que se le dio prioridad. Así, en dicho año se nombró a Brierly como relator especial, puesto que ocupó hasta su renuncia (1952). A partir de entonces se sucedieron varios relatores especiales, quienes elaboraron informes con proyectos de artículos en los siguientes períodos: Lauterpacht (1953-1954), Fitzmaurice (1956-1960), Waldock (1962-1966). Para un mayor detalle ver Villiger, Mark E., "The 1969 Vienna Convention on the Law of Treaties - 40 Years After", *R.C.A.D.I.*, vol. 344 (2009), pp. 25-32.

2 En 1969 la CDI presentó el proyecto final de artículos a la Asamblea General, recomendando que se convocara a una conferencia diplomática con el objeto de la adopción de una convención sobre el derecho de los tratados. Así, la Asamblea General, luego de discutir el proyecto que sería de base, convocó a una primera sesión de la conferencia en Viena en 1968 (Res. 2287 (XXII), del 06/12/1967).

3 Adoptada en Viena el 22/06/1969. Entró en vigor el 27/01/1980. En la República Argentina ha sido aprobada por Ley 19.865 (B.O.: 11/01/1979). El Gobierno argentino depositó el instrumento de ratificación el 05/12/1972. Paul Reuter fue nombrado relator especial.

4 Adoptada en Viena el 21/03/1986. En la República Argentina ha sido aprobada por Ley 23.782 (B.O.: 07/06/1990). El Gobierno argentino depositó el instrumento de ratificación el 17/08/1990. Aún no entró en vigor, por cuanto a la fecha no se han obligado treinta y cinco Estados, que es lo que requiere la Convención para su entrada en vigor (cfr. art. 85).